

"... Así es que pido Sr. Diputado se fije en esta distinción fundamental: esto no es para los individuos, para las acciones aisladas, ni para los derechos del ciudadano, sino para los derechos del pueblo, para ese ser colectivo que se llama humanidad..."

A la luz de los antecedentes expuestos la extensión del enunciado normativo incluye dentro de los derechos implícitos a los derechos colectivos y a la respectiva garantía que los resguarda en los supuestos de conculcación.

b) Jurisprudencia nacional

Como se ha señalado los antecedentes fueron muy cercanos a la propia creación de la Nación Argentina, pero su funcionamiento práctico judicial fue más próximo a nuestros días.

En nuestro país, una década antes de la reforma de 1994, fueron algunos jueces y tribunales (nacionales y provinciales) los que cambiaron la historia que hoy ha quedado superada, al admitir ciertas demandas, en especial en material ambiental, donde la cuestión central en debate era la legitimación procesal de estos novísimos derechos ya que los mismos exigían nuevas garantías que los protejan adecuadamente (5).

En este sentido, es preciso citar los casos "Kattan" de 1983, el conocido caso de las "Toninas Overas" y del "Agente naranja", resueltos favorablemente por sendos jueces de primera instancia sin norma constitucional expresa a partir de un amparo presentado por simples ciudadanos. Si bien en el primer caso se puede decir que fue tomada la demanda como una acción popular y en el segundo como un amparo ambiental, son verdaderos indicios de una nueva corriente doctrinaria.

Se reedita así el origen pretoriano de la acción de amparo colectivo, tal como sucedió con el amparo individual a través de las ejemplares sentencias de la Corte Suprema recaídas en autos "Angel Siri" (1957) y "Samuel Kot" (1958).

Pero fue el Alto Tribunal, en el año 1992 en el célebre caso: "Ekmekdjian c. Sofovich" quien hizo nacer el amparo colectivo en el derecho público argentino sin necesidad siquiera de una norma constitucional expresa e independiente de las leyes reglamentarias, al reconocer legitimación a una persona que invocando sus personales creencias religiosas, en rigor estaba actuando en nombre de un grupo.

c) Incorporación constitucional

Finalmente, con la reforma constitucional de 1994 se han introducido nuevos derechos de incidencia colectiva o de intereses difusos, como la discri-

(5) QUIROGA LAVIE, HUMBERTO y otros, *Derecho Constitucional Argentino*, Buenos Aires, 2001, t. I, p. 294.

minación, los enunciados en el art. 41 sobre el medio ambiente y en el art. 42 con relación a los derechos de los usuarios y consumidores, y la libre competencia de mercado.

Para ello fue necesario brindarle una herramienta eficiente para la protección de dichos derechos y siguiendo el fallo "Ekmekdjian" incorporó en el art. 43 párrafo segundo al *amparo colectivo*, aunque su denominación no figure expresamente en él.

3. DERECHO A UN AMBIENTE SANO APTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

Como ya se ha adelantado, la nueva norma constitucional avanza sobre la regulación de la acción de amparo colectivo, como consonancia de los derechos consagrados en los nuevos arts. 41 y 42, es decir amplía el ámbito de esta garantía —amparo— para que sea utilizada en la defensa de los derechos del medio ambiente, de la competencia, de usuarios y de consumidores. Asimismo irrumpe en la consideración de la problemática de la discriminación.

El art. 43 de la CN divide a los derechos protegidos en dos grandes grupos: los especiales y los generales. Los primeros son los descriptos "ut supra" y los generales son los llamados de incidencia colectiva en general, que como bien recuerda Agustín Gordillo, es la porción más rica y significativa de la nueva cláusula constitucional.

Con relación al derecho a un ambiente sano y equilibrado apto para el desarrollo humano (6), nos encontramos frente a los llamados derechos de tercera generación o de intereses difusos (7). Detrás de esta categoría de derechos subyace una gama variada de intereses de la comunidad toda, cuya violación afecta a la ciudadanía en su conjunto o por lo menos a una importante porción de ella, sin desconocer la posibilidad de que existan afectados particulares como resultado de haber sufrido un daño directo en sus personas o en sus patrimonios.

(6) Esta titulación es coincidente con una gran parte de la doctrina que está en contra de la utilización del término "medio ambiente", ya que es jurídicamente reiterativo y gramaticalmente incorrecto, o cualquier otra fórmula que contenga los vocablos indicados en la misma proposición. Las palabras "medio" y "ambiente" son sinónimos, son términos anfibológicos que, únicamente pueden aparearse cuando lo que se pretenda sea reforzar su contenido utilizando la reiteración. En pureza debe hablarse de medio-hídrico, medio atmosférico, pero no medio ambiente (MARÍN GAMEZ, J.A., *Plusprotección ambiental y el art. 45 de la Constitución Española*, Jaén, 1995).

(7) Aunque algunos autores como Quiroga Lavié no están de acuerdo con esta denominación, por pensar que el sustantivo elegido puede acarrear la incorrecta visión de que no se trata de verdaderos derechos subjetivos y porque el adjetivo elegido puede hacer pensar sobre la existencia de un titular indeterminable que termine por no nominar a nadie; en suma, ese difundido *nomen iuris* connota una magra existencia que podría hacer pensar que merecen menor protección.

Sabido es que los derechos de tercera generación persiguen la protección de intereses difusos o de derechos subjetivos públicos. Es decir de aquellos intereses que no se sitúan en cabeza de un sujeto determinado, sino que se encuentran difundidos o diseminados entre todos los integrantes de una comunidad, o inclusive de varias. Estos caracteres plantean una seria dificultad de tipo procesal en lo que hace a su defensa jurisdiccional. Se trata de determinar quién está habilitado para accionar ante la justicia, cuando no se puede invocar un interés legítimo o un derecho subjetivo para ello. Y de este modo nos introducimos en la consideración del segundo elemento invocado al comienzo, el problema de la legitimación activa (8).

El derecho constitucional va dando respuesta desde su óptica a una altísima gama de intereses generales, públicos, fraccionados, pero ciertos y con jerarquía, que requieren de una protección de marcado carácter preventivo como es característico en el derecho ambiental. Se trata de una coparticipación colectiva de intereses. En este tipo de relaciones se tiene parte en un interés colectivo y supraindividual, ello constituye la faz subjetiva de la cuestión. Es decir que si bien no se puede demostrar un perjuicio personal o actual, de todos modos quien participa de esta suerte de relación consorcial, compuesta por todos los damnificados actuales o potenciales, puede invocar una suerte de "cuota parte" que en tanto participe en la cuestión le da derecho a recurrir a la justicia.

4. LEGITIMACIÓN O SUJETO ACTIVO

Un punto a destacar es la importancia de este derecho que rompe con la prohibición de acceder a la justicia si no se encuadraba dentro de la trilogía: derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple.

La reforma constitucional del año 1994, reconoce legitimación propiamente dicha a favor de los sujetos: el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones creadas a esos fines.

a) El afectado

Este término resulta por demás enigmático y ha dado lugar a diversas interpretaciones. Por una parte, una visión restringida, estima por afectado a aquel que es titular de un derecho subjetivo. Por otra parte, la posición amplia, piensa que una interpretación conjunta de los términos "afectado" y "derechos de incidencia colectiva en general", permite suponer una consagración de la legitimación para actuar a cualquier afectado en reclamo de derechos colectivos. Se debe acreditar un mínimo interés razonable y suficiente, de conformidad con figuras similares del derecho anglosajón, para

(8) SABSAY, DANIEL (Director) - MARANIELLO, PATRICIO (coautor) entre otros, *Colección de análisis jurisprudencial —Derecho Constitucional—*, Buenos Aires, 2002.

constituirse en defensor de derechos de incidencia general o supraindividuales. El derecho subjetivo está reservado para la primera parte del artículo, en cambio en la segunda es evidente que no se contemplan agresiones o daños de carácter personal o particular, sino que se está aludiendo a derechos supraindividuales de incidencia colectiva, que no son otros que los que antes eran llamados *intereses difusos*.

Un pronunciamiento de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, sala III, 8/9/1994, "Schoeder Juan c. Estado Nacional (Secretaría de Recursos Naturales) s/ amparo" ha establecido una primer interpretación del alcance de la legitimación que establece la norma a los efectos de la defensa de intereses de tipo colectivo, al reconocer legitimación a un vecino de la localidad elegida para la construcción de una planta de tratamiento de residuos peligrosos. El vecino entra dentro de la categoría de "afectado" y se considera válida su pretensión de anular el correspondiente procedimiento licitatorio. Es decir, la interpretación del término "afectado" tanto la sentencia de primera instancia como la de la Cámara entendió que la condición de afectado quedaba cumplida con el interés personal y directo que ostentaba el actor por su calidad de vecino.

En el mismo sentido ha resuelto el Superior Tribunal de Justicia, en un fallo de 23/6/1995 en autos: "Moro Carlos Emilio y otros c. Municipalidad de Paraná s/ acción de amparo", en el que se reconoció expresamente la legitimación activa a los vecinos del parque Urquiza de la Ciudad de Paraná, contra el municipio, a fin de que se disponga el inmediato cese de las obras de construcción de un albergue municipal en un predio próximo al parque, toda vez que el accionar de dicha Municipalidad afectaba de manera manifiestamente ilegítima el goce y ejercicio de derechos constitucionales de los vecinos accionantes.

Por último con relación a este punto es de destacar la postura de Miguel Angel Ekmejdjian, quien sostuvo que, en el fondo, la discusión sobre la *class actions* o acción de clase y la acción popular es puramente semántica, puesto que depende de la extensión que se le dio al término "afectado". Si éste es el aquejado o molestado, por una acción u omisión que afecte al medio ambiente, a la competencia, a usuarios o consumidores o a las convicciones fundamentales de grupos de pertenencia, estamos ante una acción de clase. Cuando esa clase es tan amplia que puede llegar a confundirse con la sociedad toda, estamos muy cerca de la acción popular, porque habrá muy pocas personas que no tengan cabida en este concepto de afectados (9).

Tan solo agregaremos que en la acción popular además ostenta en su faz adjetiva una total desprovización de requisitos formales para su presentación. Incluso puede ser interpuesto en forma oral.

(9) EKMEJDJIAN, MIGUEL, *Tratado de derecho constitucional*, Buenos Aires, 1997, t. IV, p. 75.

b) El Defensor del Pueblo

Su habilitación es una resultante del papel que cumple este nuevo actor institucional como instancia pública de defensa de los intereses generales y como tal está legitimado para actuar ante los tribunales en defensa de los derechos de tercera generación. Se trata de una figura designada por el poder legislativo, con plena independencia y autonomía funcional, como se señaló "supra".

Su misión —según se encuentra reglado en el art. 86 de la CN— es la defensa y la protección de los derechos humanos y demás derechos y garantías tutelados por la Constitución y las leyes ante hechos u omisiones de la administración y el control de las funciones administrativas públicas, incluyendo la defensa de los intereses difusos y colectivos. Muchas cuestiones se han suscitado a partir del planteamiento de la legitimación de esta institución. Desde el grado de pertinencia de un pedido de inconstitucionalidad que formulase respecto de una ley dictada por el órgano Congreso que lo designa, hasta que su intervención podría hacer desaparecer los litigios individuales, con grave afectación al derecho de defensa, mucho se discutió en la jurisprudencia de la Corte Suprema entre 1995 y 2005 (época en la cual el Defensor fue sistemáticamente "deslegitimado" por el Tribunal) y en la doctrina en relación a su correcto rol en el juego de las instituciones de la República.

c) Asociaciones registradas

Las asociaciones de protección de los consumidores y usuarios, han adquirido legitimación constitucional para su actuar de los arts. 42 y 43, aunque el texto constitucional le ha exigido un requisito de obligatoriedad insalvable, que es la de ser registradas conforme a la ley. La fuente de ambos artículos se encuentra en los arts. 51 y 52 de la Constitución Española; sin embargo, una de las diferencias más significativas, se encuentra en que esta última establece que dichas asociaciones, tanto en su estructura interna y como por su funcionamiento, deberá ser democrático y en la Ley Fundamental Argentina deriva todo su alcance a la ley que regule su funcionamiento.

En este punto se impone esperar lo que la ley reglamentaria establezca al respecto. En particular qué exigencias de registración, entre otras, les impone a estas personas para poder constituirse en legitimadas activas de este tipo de acción. En relación con la necesidad previa de una ley que fije el tipo de asociaciones y el modo como deben registrarse, de conformidad con lo establecido en el art. 43, 2º párrafo, la jurisprudencia ha tendido a abrir con amplitud el acceso de estas organizaciones a la justicia. De modo tal que se las ha legitimado aunque la ley a que alude el constituyente no se hubiese sancionado. Se ha reconocido ese carácter tanto a organizaciones del tipo asociativo no gubernamental defensoras del ambiente o de los consumidores o de tipo cívico, entre otras, como así también a organizaciones intermedias tradicionales como son los sindicatos. Incluso en algunos casos, el juzgador no se detuvo en el análisis de las características de la asociación accionante como

por ejemplo en "Fauna Marina c. Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires", Juz. Fed. Nº II, Mar del Plata, 5/8/1996, ED, del 10/10/1997. Es de destacar que en la especie, el amparista no contaba con personería jurídica al momento de la interposición de la demanda.

Ello así, mientras la ley no se dicte y por ende, la registración no se efectúe, las asociaciones que ya están constituidas para objetivos coincidentes con los que menciona el art. 43, podrían ser judicialmente admitidas para la promoción del amparo.

Los derechos enunciados en el art. 42 de la Constitución ya estaban reconocidos antes de la reforma de 1994; el Congreso Nacional sanciona el 22 de septiembre de 1993, la ley 24.240 de defensa del consumidor, que sirve como un antecedente valioso —a tener en cuenta—. A pesar de ser anterior a la reforma constitucional de 1994 y como su contenido se adecua a las prescripciones del art. 42 de la Ley Fundamental, las disposiciones de la ley 24.240, son reglamentarias de esta última (10).

5. EFECTO "ERGA OMNES" DE SUS SENTENCIAS

Otro tema que reviste entidad, es el de los efectos de las sentencias de los tipos de accionantes citados precedentemente. La jurisprudencia ha sentado, tradicionalmente, que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma jurídica, tienen efecto sólo en el caso juzgado y no implican la derogación de esa norma (ED, 16-806).

En el caso "Blas", fallado por la sala I de la CN Contencioso Administrativo Federal el 1 de diciembre de 1997, se resolvió lo expuesto aplicando la tesis de "Monge" (LA LEY, 1997-C, 150) en materia universitaria. Es que no hay otra opción razonable que el efecto "*erga omnes*" de la sentencia; y eventuales sentencias distintas se uniformarán en su caso por un plenario merced al recurso de inaplicabilidad de la ley, o por un fallo de Corte. Resultaría absurdo sostener que los efectos de las sentencias en los supuestos a que venimos haciendo referencia no fueran "*erga omnes*", teniendo una nueva Constitución con nuevos derechos y garantías colectivas, es decir, fenómenos con nuevas dimensiones.

Hay algunos que se lamentan que estamos abandonando la democracia representativa y adoptando figuras de democracia semidirecta. Frente a ello puede decirse que no es posible desconocer que, desde la perspectiva de la reforma constitucional, se está ampliando el estrecho concepto tradicional de *parte*, propio de los procesos patrimoniales o de familia, para incursionar en uno más amplio, que se corresponde con la democracia semidirecta. De este modo se introduce el concepto de la *class actions*, diseñado por la juris-

(10) Ver MARANIELLO, PATRICIO A., "Alcances del veto parcial del Poder Ejecutivo en el tributo a la medicina prepaga...", LA LEY, del 26/5/1999.

247

prudencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y por la legislación de ese país (11).

Resulta de gran importancia que una nueva ley reglamente las acciones judiciales que tiendan a proteger los intereses de incidencia colectiva, como así también los efectos de sus sentencias, después de la reforma de 1994, por la Constitución Nacional (12).

Sobre esta temática, hay que tener muy en cuenta que los mencionados efectos tienen un *"animus adiuuandi"*, es decir, que en el caso que una persona, tenga un interés en la acción y no esté conforme con el actuar o con el resultado obtenido por las entidades accionantes, pueda iniciar una acción en forma independiente, siempre que ésta no haya sido parte en el juicio en forma directa —otorgando un poder a la accionante para que lo represente en juicio— o indirecta —estar asociado o ser miembro de la organización demandante—, ya que, de otra forma se estaría violando el art. 43 párrafo segundo de la Constitución Nacional, donde se le asigna la potestad de interponer la acción de amparo tanto al Defensor del Pueblo y Asociaciones como al "afectado", es decir, que no se podrá excluir la posibilidad de que el "afectado" en forma independientemente inicie dicha acción.

Recordemos, en esta línea y como ya hemos visto, que el art. 30 de la ley 25.675 señala que: *"Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el art. 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su intervención como terceros. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras del daño ambiental colectivo"*.

Un interrogante a plantear cuya respuesta excede este marco, pero que resulta ilustrativo formularlo, sería el caso de una persona que por el mismo hecho por el cual el Defensor del Pueblo o Asociación Colectiva ha iniciado una acción, no se considera "afectado" por aquél, sino, más aún, "beneficiado": ¿qué actitud podría tomar esta persona frente a la representación invocada por el órgano o entidad precitada?

Por lo pronto tendría la posibilidad de iniciar una nueva acción, y tan solo la sentencia que le fuese favorable puede tener efectos *erga omnes*.

(11) V. BIANCHI, ALBERTO, *Las acciones de clase*, Buenos Aires, 2001.

(12) MARANIello, PATRICIO A, op. cit.

6. LA CREACIÓN DE UN VERDADERO AMPARO AMBIENTAL

Argentina ostenta una gran variedad de "amparos". En lo nacional, encontramos al amparo individual, al colectivo, al sindical, al electoral, y ahora al ambiental. Veinticinco jurisdicciones tienen acción de amparo a nivel local, lo cual lleva a decir a Eduardo Ferrer Mac Gregor que nuestro país muestra "una variedad de tipos de amparo sin parangón en Iberoamérica" (13).

Como podemos notar, en el amparo ambiental existen particularidades especificadas tales como: el derecho protegido, la legitimación activa y también pasiva para accionar a la justicia en protección del derecho conculcado y los efectos de su sentencia. Estamos frente a un amparo muy específico que no puede estar dentro de un amparo individual sino que es un amparo con características y regulaciones propias; es por ello que consideramos que existe un amparo general llamado "amparo de incidencia colectiva" y dentro de éste se encuentra el "amparo ambiental".

El amparo ambiental si bien tiene como matriz al amparo de incidencia colectiva, reviste características muy particulares que hacen su regulación específica.

Entre éstas debemos destacar lo regulado por la Ley General del Ambiente 25.675, sancionada en el año 2002, donde entre sus muchas y variadas temáticas tiene algunas cuyas peculiaridades nos lleva a fundamentar su especificidad procesal y sustantiva.

El art. 32 de la ley citada nos indica que *"... el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie..."*. Aquí la aplicación del *pro actione* no sólo es un principio más del derecho, sino es el principio rector de toda acción ambiental, empalmándose con la noción de acceso a la justicia, sin que los jueces puedan rechazar *in limine* por defectos formales en aras de protección al libre e irrestricto acceso a la justicia y la búsqueda de la *verdad material*.

Continúa el artículo diciendo *"... el juez podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. En cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida preparatoria, podrá solicitarse medidas urgentes, aún sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudiera producirse..."*.

Este punto está diseñado a los fines de que el juez interviniente salga de su rol neutral, pasivo, legalista y espectador del proceso para convertirse en parte del proceso con un mayor compromiso social y de protección integral de los derechos en juego, para nuestras generaciones y las futuras. Como dice

(13) FERRER MAC GREGOR, EDUARDO, "Breves notas sobre el amparo iberoamericano", en DIEGO VALADÉS y otro (Editores), *El Estado Constitucional Contemporáneo*, México, 2006, t. II, p. 527.

262

Morello (14) el proceso colectivo exige un *aggiornamento* de técnicas jurídicas diferenciadas, flexibles, menos formalistas y más teleológicas, o a lo que el mismo autor llama proceso vivo (15).

Además de regular las conocidas medidas cautelares, que se pueden solicitar en cualquier estado de un proceso ya iniciado, se incorporan las "medidas preparatorias" que son medidas cautelares anticipatorias a la iniciación de una acción de amparo posterior, que por su urgencia y peligrosidad no pueden esperar a la formación de una causa principal, donde sus plazos y sus formalidades son exigüos en su faz limitativa.

Por otro lado, el art. 33 de la misma ley, estipula que la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efectos "erga omnes", a excepción que sea rechazada, aunque sea parcialmente por cuestiones probatorias.

A nuestro entender, la sentencia debe ser eminentemente consecuen-
cista y sustentable, en cuanto no puede resolver las cuestiones sin tener en cuenta a las generaciones presentes y a las futuras. Aquí tenemos la injerencia de los principios de equidad intergeneracional y de sustentabilidad, regulados en:

1. Informe de Brundtland de 1983,
2. Art. 41 de la Constitución Nacional,
3. Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre medio ambiente,
4. Principios 3, 4 y 8 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
5. Acta de Conformidad 151/05 de las Conferencias de las Naciones Unidas de 1992, y
6. Art. 4º de la Ley General del Ambiente.

7. CONSIDERACIONES FINALES

Si decimos que los derechos de incidencia colectiva tienen como garantía el amparo colectivo, y dentro de los derechos de incidencia colectiva están los derechos ambientales su garantía no podría ser otra que el amparo ambiental, con elementos particulares y específicos, como son: los efectos *erga omnes*, la revisión de la cosa juzgada, la amplitud de la legitimación activa y pasiva y la aplicación del principio precautorio y preventivo. Sin olvidarnos del nuevo rol del juez de la causa, con una participación más pro-activa y más

(14) MORELLO, AUGUSTO, *Del proceso individual al proceso colectivo*, La Plata, 1999, ps. 37 y sigtes.

(15) V. MORELLO, AUGUSTO M. y CAFFERATIA, NÉSTOR, *Visión procesal de cuestiones ambientales*, Buenos Aires, 2004, p. 199.

protectora del proceso, como un verdadero garante del llamado "interés general internacional".

Es por ello que el *amparo ambiental* del art. 43, 2º párrafo, nos parece una herramienta autónoma y de particular utilidad para posibilitar la apertura de la justicia a la defensa de derechos a un ambiente sano y equilibrado que proteja el desarrollo humano con sustentabilidad para las generaciones presentes y futuras.

Un instituto de este tipo debería constituir un instrumento capaz de controlar los desbordes que en el ámbito de la vigencia de los derechos fundamentales y en particular, del principio de igualdad, presenta el debilitamiento de las estructuras estatales, de resultados de la consagración del actual modelo económico. Al mismo tiempo, el amparo colectivo debería servir para fortalecer a la sociedad civil (16). Ello, no sólo desde una visión individual, sino también desde el sector no gubernamental y por lo tanto desde el universo de organizaciones que lo componen.

La existencia de una importante corriente doctrinaria en lo jurídico, avallada por la opinión de muchos de los más prestigiosos publicistas argentinos, ha servido para situar a la nueva figura y en especial, al alcance de quienes están legitimados para interponerla, en un punto ideal para dar cumplimiento a los objetivos de participación y de control a que hacemos mención en los puntos anteriores. Asimismo, desde la jurisprudencia estamos observando importantes fallos que desde las diversas instancias judiciales, se han pronunciado en el mismo sentido que la apuntada doctrina de los autores. Sin embargo, estas señales positivas, no pueden dejarnos perder de vista los riesgos que se ciñen sobre el amparo colectivo. En efecto, una corriente doctrinaria minoritaria tiende a interpretar su alcance con la mayor restricción posible.

Finalizando este capítulo nos gustaría decir que el hombre tiene como deber principal cuidar nuestro planeta y no tomarlo como una herramienta de explotación personal y económica, sino tomarlo como algo que no es propia y que debe mejorar y cuidar, obteniendo los limitados frutos que en ella se encuentra. Al respecto resulta esclarecedor las precisas palabras de Juan Pablo II cuando establece que "... en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él..." (17).

(16) Es que el amparo es una garantía que puede ser considerada como "estratégica". V. CARNOTA, WALTER F., "Nuevas dimensiones de los procesos constitucionales. La acción de amparo colectivo", en BIDART CAMPOS, GERMÁN J., y otro (Coordinadores), *El Derecho Constitucional del s. XXI (Diagnóstico y Perspectivas)*, Buenos Aires, 2000, p. 404.

(17) JUAN PABLO II, *Encíclica Centesimus annus*, del 1º de mayo de 1991, N° 37.

CAPITULO V

LOS PROCESOS COLECTIVOS PARA IBEROAMÉRICA (1)

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Caracterización jurídica o encuadre jurídico general. — 3. Contexto procesal. — 4. Acción colectiva. — 5. Amparo Colectivo. — 6. Derechos de incidencia colectiva general, supuestos contemplados. — 7. Recaudos de admisibilidad subjetiva para la demanda colectiva. — 8. Recaudos de admisibilidad objetiva. — 9. Trámite. — 10. Un planteo innovador: relación jurídica continua vs. efectos de la cosa juzgada. — 11. Especialización judicial.

I. INTRODUCCIÓN

El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal aprobó en Caracas el 28 de octubre de 2004, un Código de Procesos Colectivos para Iberoamérica que consta de 41 artículos.

Entre ellos contiene los siguientes temas: art. 1º: Ambito de aplicación; art. 2º: Requisitos; art. 3º: Legitimación activa; arts. 4º a 8º: Proveimientos jurisdiccionales; art. 12: Pruebas; art. 15: Costas y honorarios; art. 16: Procesos de trámite prioritario; art. 17: Interrupción de la prescripción; art. 18: Efectos de la apelación; art. 19: Ejecución definitiva y ejecución provisional; art. 20: Pretensión colectiva de responsabilidad civil; art. 21: Citación y notificaciones; art. 22: Sentencia de condena; art. 23: Liquidación y ejecución individual; art. 24: Ejecución colectiva; art. 25: Competencia para la ejecución; art. 26: De los pagos; art. 27: Liquidación y ejecución por los daños globalmente causados; art. 28: Concurrencia de créditos; art. 29 a 32: Conexidad, litispendencia y cosa juzgada —activa y pasiva—; art. 30: Litispendencia; art. 31: Relación entre la acción colectiva y las acciones individuales; art. 32: Conversión de las acciones individuales en una acción colectiva; art. 33: Cosa Juzgada; art. 34: Relaciones Jurídicas continuas; art. 35: Acciones contra el grupo, categoría o clase; art. 36: Cosa juzgada pasiva: intereses o derechos difusos; art. 37: Cosa juzgada pasiva o derechos individuales homogéneos; art. 38: Aplicación su-

(1) CARNOTA, WALTER y MARANIELLO, PATRICIO, "Comentario al Código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica", Revista de Derecho Ambiental N° 6, Buenos Aires, N° 6, abril-junio de 2006, p. 259 y sigtes.

pletoria de las acciones pasivas; art. 39: Principios de interpretación; art. 40: Especialización de los magistrados y art. 41: Aplicación subsidiaria de las normas procesales generales y especiales.

El presente capítulo además de analizar las temáticas novedosas de su articulado, nos suscita como primera pregunta determinar dos cuestiones liminares: en primer término, si estamos en presencia de una norma internacional con fuerza vinculante, o si por el contrario se trata de un conjunto de reglas modelo que deben ser receptadas por el ordenamiento interno. En segundo lugar establecer su ubicación jerárquica dentro de la pirámide jurídica.

2. CARACTERIZACIÓN JURÍDICA O ENCUADRE JURÍDICO GENERAL

Respecto a si estamos en presencia en una norma internacional con fuerza vinculante, o si por el contrario se trata de un conjunto de reglas modelo que deben ser receptadas por el ordenamiento interno, la redacción del proyecto nos persuade que estamos en presencia de un proyecto de normativa común y no de un tratado internacional, susceptible de adopción por los órdenes jurídicos internos. Hasta tanto no se opere efectivamente esa recepción estaremos en presencia de una fuente material del derecho ambiental internacional, consistente en un conjunto de sugerencias doctrinarias o derecho comparado. Una vez que la legislación o eventualmente una reforma constitucional (nacional o provincial) la incorpore al ordenamiento interno nos hallaremos ante una fuente formal, con el respectivo valor jurídico, a saber: ley nacional o provincial, constitución provincial o nacional.

Por otro lado, lícito es preguntarse el marco de supletoriedad entre este proyecto y normas procesales o adjetivas locales, lo cual obliga a una tarea de interpretación armonizante entre los distintos sistemas jurídicos, donde el grado de amplitud y flexibilidad de la norma interna juega un papel preponderante. Todo ello en el marco de la compatibilidad de sus normas, a tenor del art. 41 del Modelo de Código, donde permite la aplicación subsidiaria de este código siempre que no fuere incompatible con las disposiciones del Código Procesal Civil y de la legislación especial pertinente.

Esta técnica es practicada en otras ramas del derecho como el tributario (Modelo de Código Tributario OEA/BID —Washington DC 1968—) o comercial (UNICITRAL). En materia tributaria en nuestra legislación al no tener una definición por ejemplo de lo que es un tributo, impuesto, tasa y contribución, la doctrina y la jurisprudencia se ha inspirado en la utilización del modelo de código citado para conceptualizar dichas materias.

3. CONTEXTO PROCESAL

Tradicionalmente, las legislaciones procesales de los Estados Iberoamericanos han sido concebidas partiendo de la matriz del litigio individual, y

puntual, entre un actor y un demandado determinados. Excepcionalmente, se han admitido pluralidad de accionantes y accionados (v.gr. en un litisconsorcio). Con mucha más dificultad, se han receptado los llamados "acciones o procesos colectivos" (2) como se encuentra expresamente determinado en el art. 1° del Código Modelo en análisis.

4. ACCIÓN COLECTIVA

El título del art. 1° al expresar acción colectiva, como garantía de los intereses o derechos difusos e individuales homogéneos, es comprensiva de los diferentes procesos colectivos, a saber: amparo colectivo, acción declarativa, medidas cautelares, diligencias preliminares y el novedoso habeas corpus correctivo colectivo, reconocido por nuestra Corte Suprema de Justicia en el fallo "Verbtsky". Este último se ubicaría como garantía de protección de los derechos individuales homogéneos de que son titulares todo el conjunto de personas que cumplen una condena judicial, problemática que interesa tanto al Derecho Procesal Penal y Constitucional, como asimismo al Derecho Ambiental.

5. AMPARO COLECTIVO

Dentro de las más recientes elaboraciones del constitucionalismo latinoamericano, se ha pergeñado la figura del "amparo colectivo" (3) que, con diversos matices, procura lograr una tutela judicial efectiva respecto de los llamados "derechos de incidencia colectiva en general".

6. DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA GENERAL: SUPUESTOS CONTEMPLADOS

Precisamente, el presupuesto lógico sobre el que descansa todo tipo de remedio procesal grupal es una categoría de derechos más abarcativa (4) que la clásica relación que une a particulares, como espejo de la relación sustancial (civil) entre acreedores y deudores.

(2) V. CARNOTA, WALTER F., "¿Auge de los procesos grupales?", LA LEY, 2003-A, 1300.

(3) Sobre el amparo en su versión colectiva, tal como se encuentra regulado por el art. 43, párr. segundo, de la Constitución Nacional de 1853-1994, véase CARNOTA, WALTER F., "Nuevas dimensiones de los procesos constitucionales. La acción de amparo colectivo", en AA.VV., *El Derecho Constitucional del Siglo XXI*, Buenos Aires, 2000, p. 403; ver asimismo MARANIELLO, PATRICIO A., "Génesis y actualidad del derecho colectivo", en "Verba Iustitiae", núm. 17, Morón, p. 87, publicado como "Génesis y actualidad del amparo colectivo en Argentina", en Revista Jurídica del Perú, Trujillo, núm. 51, octubre de 2003, p. 133.

(4) Para su análisis, ver CARNOTA, WALTER F., "Derechos de incidencia colectiva en general", LA LEY, 2003-B, 280; CAFFERATA, NÉSTOR, "Derechos de incidencia colectiva", en www.eldial.com, suplemento de derecho público.

245

La dificultad de aprehender el vínculo que ata a los "miembros de una clase" queda evidenciada en el art. 1º del proyecto bajo glosa, cuando refiere dos situaciones muy bien delimitadas al menos desde un plano conceptual. Por un lado, menciona a las "pretensiones de tutela" de "intereses o derechos difusos", entendiendo por estos últimos a los supraindividuales, de naturaleza indivisible, titularizado por un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho o de derecho. También comprende la hipótesis de "intereses o derechos individuales homogéneos", en donde subyace un conjunto de derechos subjetivos individuales de origen común (conf. art. 1º, "in fine").

7. RECAUDOS DE ADMISIBILIDAD SUBJETIVA PARA LA DEMANDA COLECTIVA

Claro está que la demanda colectiva se enfrenta con complejos recaudos. Desde una faz subjetiva, requiere la "adecuada representatividad del legitimado", lo cual connota algunos problemas similares que contienen las "class actions" en el derecho norteamericano (5). Por el otro, se exige la "relevancia social de la tutela colectiva" (art. 2º, inc. II). Es éste un punto neurálgico, ya que hace al "impacto grupal" que la pretensión conlleva.

En el plano subjetivo, no sólo se pide "representatividad", dada en el párr. 2º del art. 2º citado por: a) la credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del recurrente, b) sus antecedentes en la protección judicial, c) su conducta en otros procesos colectivos, y d) el tiempo de constitución de la asociación, sino más concretamente "legitimación", abriéndose en el art. 3º un amplio abanico, empezando por las personas físicas y miembros del grupo que redundantemente aparecen en los incs. I y II, como así también los ministerios públicos, las defensorías del pueblo (6) y públicas, las personas jurídicas internas, los sindicatos, las asociaciones con estos fines y los partidos políticos.

Una novedad, entonces, por sobre nuestro art. 43, es la legitimación activa reconocida a favor de los partidos políticos y de los gremios, que esgrimen derechos que bien pueden tener aristas colectivas.

(5) Paradojalmente, Estados Unidos ahora limita las "class actions", cuando Iberoamérica intenta ir en esa dirección. Señalemos que la "Class Action Fairness Act" sancionada en febrero de 2005, limita la interposición de estos remedios en sede local cuando los reclamos tengan alcance inter-jurisdiccional en razón de las personas. V. BRUBIN, RICHARD A., "U.S. law restricts citizens' chances to go after big corporations in court", en *Federations*, vol. 4, núm. 4, Ottawa, junio de 2005, p. 11. Sobre las "class actions" en general, ver BIANCHI, ALBERTO B., *Las acciones de clase (Una solución a los problemas procesales de la legitimación colectiva a gran escala)*, Buenos Aires, 2001.

(6) Históricamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no legitimó al Defensor del Pueblo para interponer amparo colectivo, pese al tenor literal de los arts. 43, párr. 2º y 86 del CN. Una expectativa se abre a partir del pronunciamiento recaído en autos "Defensor del Pueblo c. ENERGAS" del año 2005, como ya vimos con antelación.

Del mismo modo, se legitima, tal como se anticipó, al Ministerio Público de manera amplia en el párrafo tercero del art. 3º del Modelo de Código, ya que allí se prevé que en caso de interés social relevante este órgano, si no promoviera la acción o no interviniera como parte, actuará obligatoriamente "como fiscal de la ley". Suscita un arduo problema de interpretación el hecho que la legalidad pudiera no coincidir con la constitucionalidad, planteándose al respecto las mismas dudas que exhibe el art. 120 de la Constitución Nacional sobre las funciones del Ministerio Público en el control de la actividad estatal cuando se vulnerase algún precepto de cuño constitucional.

Contrasta este rol con el que le asigna el proyecto de ley de amparo colectivo elaborado por Augusto Morello, en su art. 6º "in fine" por el cual en caso de desistimiento o abandono de la acción por parte de los legitimados activos, la defensa de los intereses colectivos será asumida por el Defensor del Pueblo de la Nación.

8. RECAUDOS DE ADMISIBILIDAD OBJETIVA

El art. 2º, entonces, habla de la *relevancia social de la tutela colectiva*, caracterizada por: a) la naturaleza del bien jurídico afectado, b) por las características de la lesión, o c) por el elevado número de personas perjudicadas. Y para los derechos o intereses individuales homogéneos, además de los citados, es también necesaria la demostración del predominio de las cuestiones comunes sobre las individuales y la utilidad de la tutela colectiva en el caso concreto.

En este aspecto cabe interrogarse si el juez *podría* o bien *debería* rechazar una demanda por falta de relevancia social de la tutela colectiva deducida. La respuesta estará en función de las distintas concepciones de la judicatura que se tenga, incidiendo el mayor o menor margen de "activismo judicial" que el sistema permita.

En el proyecto originario de la Ley General del Ambiente (art. 32) se preveía que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitiría restricciones de ningún tipo o especie. Si bien la extensión de la decisión a cuestiones no propuestas fue vetada por el Poder Ejecutivo, cabe destacar que la intención de este último órgano, fue la de facilitar la tarea del juez en su tarea discrecional de admisión o de rechazo en las acciones colectivas.

9. TRÁMITE

Dentro de la tramitación, destacamos dos reglas. Por un lado, el art. 11 ordena una audiencia (7) preliminar, y en el art. 12 se establece que la carga

(7) V. CARNOTA, WALTER F., y MARANIELLO, PATRICIO A., "La audiencia pública como medio probatorio en materia de derecho ambiental", en *Revista de Derecho Ambiental*, núm. 2, Buenos Aires, abril-junio de 2005, ps. 1 y sigtes.

296

de la prueba incumbe a la parte que posea conocimiento científico, técnico o información específica sobre los hechos o mayor facilidad para su demostración. Ello no obsta a la producción oficiosa. Claramente, estamos en el campo de la teoría de las "cargas dinámicas", ya que atañe su realización a quien se encuentre mejor posicionado en el proceso para ello.

10. UN PLANTEO INNOVADOR: RELACIÓN JURÍDICA CONTINUA VS. EFECTOS DE LA COSA JUZGADA

Sobre el particular el art. 33 y siguientes del Modelo de Código distinguen cuestiones generales y cuestiones particulares. Dentro de las primeras cabe señalar que la norma mencionada establece que la sentencia hará cosa juzgada "erga omnes". Aclara el último inciso que la competencia territorial del juez no implicará limitación para dicho efecto expansivo de la cosa juzgada.

Como cuestiones particulares se exceptúan de dicha regla a supuestos de: 1) insuficiencia de pruebas, caso en el cual cualquier legitimado podrá intentar otra acción con idéntico fundamento si se valiere de otra prueba; 2) en la hipótesis de rechazo basado en las pruebas producidas, cualquier legitimado podrá intentar otra acción en el plazo de 2 años desde el conocimiento de nueva prueba superveniente que no hubiera podido producir en el proceso y que sea idónea, 3) en el caso de intereses o derechos individuales homogéneos y difusos, en caso de rechazo de la acción se podrá iniciar la indemnización a título personal. Del mismo modo es aplicable a las sentencias penales condenatorias.

En efecto, mientras que el art. 36 contempla la hipótesis de cosa juzgada *erga omnes* en materia de intereses o derecho difusos, el art. 37 divide la cosa juzgada en materia de cosa juzgada de intereses o derechos individuales homogéneos en dos efectos: la cosa juzgada tendrá eficacia *erga omnes* en el plano colectivo, pero la sentencia que acoja la demanda no vinculará eventualmente a los miembros del grupo en su esfera jurídica individual, que podrán plantear pretensiones o defensas propias en el proceso de ejecución para dejar sin efecto la eficacia de la decisión en su esfera jurídica individual.

Unido a esta temática, el art. 34 incorpora las llamadas "*relaciones jurídicas continuas*", es decir, si en un caso sobreviniere modificación en el estado de hecho o de derecho, la parte podrá pedir la revisión de lo que fue decidido en la sentencia, lo cual haría una excepción a los principios de cosa juzgada sentados precedentemente.

Al respecto, en nuestra legislación, la Ley General del Ambiente en el art. 33 establece que: "la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto 'erga omnes', a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias".

Sobre el punto la doctrina (8) ha sostenido que "los alcances de la cosa juzgada o la oponibilidad de la condena deben tener potencia expansiva suficiente a tono con la materia que hace al contenido de la tutela jurisdiccional, sin perjuicio de autorizar el nuevo planteo de la misma acción en un plazo que la ley fijará, cuando la sentencia denegatoria se funda en ausencia de prueba suficiente o falta de legitimación de obrar".

11. ESPECIALIZACIÓN Y ROL DEL JUEZ

Finalmente, el art. 40 establece que siempre que sean posibles, los procesos colectivos serán procesados y juzgados por magistrados especializados. Aquí sería conveniente crear un Fuero de Procesos Colectivos, divididos por diferentes materias como ser: ambiental, usuarios y consumidor y discriminación. La especialidad no sólo ayudaría a englobar todas las acciones en un mismo fuero, sino también a jerarquizar su desarrollo y evolución jurídicos.

Desde esta perspectiva, el panorama comparativo acusa una modalidad de tutela que se orienta hacia un juez con "responsabilidad social" o sea independiente pero comprometido, no desde luego con la orientación política circunstancial del gobierno del Estado sino con el sentido de ayudar a facilitar, lógica y razonablemente, la trascendente evolución del derecho. Un juez que está en el centro del ring pero no ya en la actividad neutral (la del *referé*) sólo para impedir los "golpes bajos". Ha quedado atrás esa posición de mero mediador, de asegurador o garantía del juego formal y privatístico de los contendientes (9). Una nueva cultura jurídica adversarial; más simple, informal, que relativiza el rigor pretendidamente absoluto y cerrado de los principios; nada conceptualista ni abstracto, en donde el juez pierde neutralidad que es una manera disfrazada de conservadurismo y manteniendo desde luego total independencia y objetividad, axiológicamente está personalmente comprometido a que los resultados de la jurisdicción sean más justos y útiles. Del protagonismo del juez y de la forma de conducirse y estimular la colaboración debida por los otros sujetos del proceso. Director inmediato y no distante, que maneja poderes-deberes de uso inaplazable, que busca la verdad jurídica y que en temas de especial connotación social, no sólo aguarda la puntual satisfacción de las cargas probatorias dinámicas y de colaboración real de los interesados, sino que, además llega a comportarse como cabal investigador, si bien lo que él obtenga a través de ese rol deberá ser puesto, bilateralmente, a disposición, observación y control de las partes.

En este íter la cuña gravitante de la transformación del servicio de la función de juzgar y al cabo del Poder Judicial, se radica en la nueva posición y

(8) MORELLO- BERZONCE- HITTERS, *La Justicia entre dos épocas*, La Plata, 1983, p. 233.

(9) MORELLO, AUGUSTO M., "Experiencias y alternativas para repensar y asegurar la eficacia del servicio", cap. XL, p. 622, 623, en *Estudios de Derecho Procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas*, vol. 1, La Plata, 1998.

actitud del juez y en el modo de aplicar la teoría de la interpretación de las normas. El perfil y las diferencias del juez liberal con un juez de "acompañamiento", esto es, el juez "entrenador" o "protector", se dibuja mediante un conjunto de factores. Asistimos al embate de nuevas olas. A un dinamismo acentuado, que se aúna a la voluntad positiva de adaptación, a receptar los cambios que reclaman las nuevas exigencias de la sociedad" (10).

12. CONCLUSIÓN

Como vemos este modelo de Código, si bien tiene una caracterización jurídica por la cual lo torna una fuente material en materia procesal ambiental, resulta un instrumento novedoso en los temas como tales como: los recaudos de admisibilidad subjetivos y objetivos, la relación jurídica continua, y la especialización judicial.

En América Latina los procesos colectivos han sido de muy lenta elaboración a cuyo desarrollo esperamos contribuya este proyecto de manera decisiva, para su incorporación legislativa en forma definitiva en el ámbito interno, desplegando a su modo claras mandas constitucionales.



CAPITULO VI

CONCEPTOS ANTIGUOS Y MUNDOS NUEVOS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Globalización y puntos de encuentro en el derecho constitucional comparado. — 3. Cláusulas pétreas. — 4. El derecho, la economía y los derechos sociales. — 5. Los derechos de las minorías y pueblos indígenas. — 6. Federalismo. ¿Derecho constitucional subnacional o de la descentralización? — 7. Puntos de encuentros y reflexiones finales.

1. INTRODUCCIÓN

El título del epígrafe es el que fue utilizado por el VI Congreso Mundial del Derecho Constitucional que tuvimos el honor de participar. El mismo se desarrolló entre los días 11 y el 16 de Enero del año 2004 en Santiago de Chile, organizado conjuntamente por la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC) y la Asociación Chilena de Derecho Constitucional.

Nunca un título resultó tan significativo para enunciar un congreso mundial de derecho constitucional, porque los académicos no sólo deben tener en cuenta el pasado y el presente sino el futuro, como un modo de adelantarse y fijar las nuevas perspectivas comunes a todos los Estados de un derecho que por cierto es de vital importancia para todo país que se precie de ordenado, integrador, moderado, ético, justo e igualitario.

El evento contó con la participación de 450 expertos de 60 países. Entre los 180 que provenían de países de Latinoamérica, la delegación más numerosa era naturalmente la de Chile, con 90 asistentes; mientras que la delegación argentina fue la segunda en número (30 asistentes) y la integraron, entre otros, los profesores Antonio María Hernández, Walter Carnota, Patricio Maraniello, María Cenicacelaya, Carlos Mayón y Pablo Riberi.

Lo desarrollado en dicho congreso junto con las ideas vertidas en el VII Congreso Mundial de Derecho Constitucional celebrado en 2007 (con la asistencia de 600 participantes provenientes de 70 países), son los puntos estructurales de este último capítulo que por su actualidad e ideas transcendentales del derecho constitucional comparado hemos considerado sea la última parte de esta obra.

(10) Ver CAFFERATTA, NÉSTOR, *Ley 25.675 General del Ambiente, comentada, interpretada y concordada*.

Se deja aclarado que las presentes reseñas sintetizan a grandes rasgos y en algunos casos sin nombres propios; algunas ideas vertidas en las Conferencias plenarias, en los talleres y en conversaciones informales posteriores de los congresos citados. Dada su índole informativa, no es posible ni sería pertinente glosar aquí el contenido de las conferencias *in extenso* o hacer una recensión de las ponencias presentadas.

2. GLOBALIZACIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTROS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

Numerosos fenómenos contemporáneos comprometen el concepto tradicional de Estado. Se trata, por ejemplo, del significado y relevancia de las organizaciones internacionales supranacionales, de las demandas intraestatales por una mayor autonomía local, de la movilidad internacional de las personas, del dinero y de la información así como de los poderes del sector privado, bajo formas muy variadas. Al menos, los fenómenos aludidos parecen exigir una reformulación de la noción tradicional de soberanía del Estado, frente a ellos y otros semejantes. Al mismo tiempo, sin embargo, diversos factores, tanto nacionales como internacionales fortalecen la relevancia del Estado. Al inicio del siglo XXI cabe, por ende preguntarse ¿en qué medida y para cuáles objetivos los conceptos, hoy vigentes, de naturaleza y el papel del Estado deben ser revisados?

En el Congreso de Santiago de Chile, el profesor de EE.UU. *Joseph Weiler* dijo que no hay que preguntarse sobre la importancia de los Estados, sino de qué modo influyen los Estados en un proceso de integración en un mundo cada más globalizado.

Los ejemplos lo tenemos con Bélgica y Luxemburgo: cuando no están de acuerdo de algo en la Unión Europea su voluntad vale más que cuando estaban aislados de la comunidad.

En 1950 no era un tema trascendental la importancia que revisten los Estados. El derecho consuetudinario se basa en un consentimiento tácito o implícito de los Estados en el proceso de integración o globalización.

¿Hay que cumplir la ley internacional? Los Estados se enfrentan entre el gobierno internacional, donde hay gobernabilidad sin gobierno, o el gobierno nacional donde no hay gobernabilidad pero sí gobierno.

El tema es la legitimidad, cuando existe un gobierno se tiene que elegir democráticamente, porque la constitución se fundamenta en el *demos* Francés, Alemán, Español, que es diferente. Es una diferencia antológica. No hay un *demos* internacional liberal, social, etc... La separación de poderes necesita una división y un gobernante. El desafío es que tenemos un gobierno internacional; pero no tenemos gobernabilidad internacional. Donde hay gobierno no hay legitimidad democrática.

El tema no es administrativo, ni constitucional, es internacional. ¿Quién gobierna? Los Estados NO. Hay que redefinir la gobernabilidad.

La conclusión sería no hay forma hoy para reemplazar a los Estados.

El profesor alemán *Jochen Frowein* dice que la transferencia de legitimidad ocurre cuando actúa la justicia internacional, así como las normas de derecho internacional.

Las elecciones nacionales dan legitimidad a la Unión Europea cuando eligen los parlamentarios europeos; esto sería una democracia en sentido amplio.

La Unión Europea no es una comunidad de Estados sino de ciudadanos, aunque en su forma representativa y republicana.

En otros talleres y conferencias centrales o principales, buena parte de las intervenciones estuvieron dedicadas a la intuición, donde la diversidad del derecho constitucional (aquellos de que, como decía Hobbes, cada pueblo habla *su propia lengua* del bien y del mal) tiende hacia un punto de convergencia que se hace notar por distintos factores.

- En primer termino, el fenómeno (extrajurídico) de la globalización, que genera una pulsión de uniformidad en todas las sociedades y por carácter transitivo en su derecho.

- En segundo lugar, las influencias *verticales* que ejerce la comunidad internacional organizada sobre el Estado-Nación, con acentuada gravitación en el caso de las organizaciones regionales.

- En tercer lugar, las influencias *horizontales* que se dan entre países que van copiando sus sistemas y evolucionando a través de la prueba, el error y la imitación: caso paradigmático es la Constitución Española de 1978, que combinó en un híbrido soluciones constitucionales de distintos países; en forma similar, podrá argüirse, se ha procedido con los institutos incorporados en nuestra reforma constitucional de 1994.

Ello demuestra que los procesos de constitucionalización reconocen reajustes e influencias recíprocas. Y, junto a ello, la idea generalizada era la de marcar, por debajo de esas influencias, las tendencias de diferenciación y las variopintas formas de asimilación que se observan tanto en el derecho sustantivo como en el derecho procesal constitucional. Así, varias ponencias de nuestro país señalaron cómo en el derecho argentino las influencias han sido reinterpretadas en el orden doméstico alejándose en la práctica de sus precedentes, tanto jurisprudenciales como constitucionales.

También se apuntó que las inspiraciones extranjeras no son necesariamente virtuosas, ya que a veces no resultan sino intentos de encontrar soluciones superficiales y rápidas, articulando el fácil recurso a una solución foránea supuestamente exitosa.

Si es harto complejo orientarse en la búsqueda de un *ius cogens* vinculante, también fue igualmente difícil encontrar coincidencias en el taller consa-

grado a los "Principios Constitucionales no Escritos". Sin ahondar en una amplia esquematización de las posiciones expresadas, puede decirse que la visión mayoritaria encontraba plausible la existencia de un lenguaje común del derecho constitucional, *residual*, que no es más que el resultado de que los dialectos constitucionales de cada nación tienen un núcleo compartido o compatible, fundado en valores.

La otra posición (para algunos, contraria y para otros, complementaria) es aquella que entiende que la parte realmente vinculante en el derecho comparado no está dada por la difusa herencia que nos han legado los "viejos conceptos", sino por la formación de un derecho común *incipiente* que resulta de las presiones hacia la homogeneidad que imponen los "nuevos mundos". Adviértase que de acuerdo a esta última posición los principios constitucionales no escritos surgirían (tácitamente) a través de la uniformidad de la práctica, independientemente de la justificación conceptual que los sustente en el plano teórico.

3. CLÁUSULAS PÉTREAS

Muchas palabras se vieron reflejadas en esta temática, donde muchos analizaron las bondades de que encuentre una cláusula específica que establezca la posición contraria de una modificación total de la Constitución y se exprese la prohibición de reforma de los principios, derechos y garantías esenciales de un estado.

Ello se apoyó en la idea de que por más que se cambie de gobierno y de políticas de estado los derechos elementales e indispensables de los ciudadanos no se encuentren a merced de ideas políticas autoritarias que quieran limitarlos.

Con ello, estamos convencidos, que estaremos creando dos categorías de Poder Constituyente, los de primer grado y los de segundo grado. En los primeros ubicados los constituyentes creadores de la Constitución y de las cláusulas pétreas. Mientras que los de segundo grado son los posteriores que se ven sometidos y limitados por los primeros. Es por ello que creemos que al existir otras maneras de cuidar o custodiar los derechos (jurisdicción internacional, regional u organismos exteriores) no sería justo que nosotros los ciudadanos del presente nos veamos sometidos a derechos o ideas sin poder reempezar o crear nuevas estructuras o regulaciones más adecuadas a nuestra época. Por qué no poder pensar en una nueva República, un moderno sistema democrático, un federalismo integrador o una forma de gobierno innovadora.

4. EL DERECHO, LA ECONOMÍA Y LOS DERECHOS SOCIALES

Los derechos sociales y económicos son generalmente reconocidos como metas que los gobiernos tratan de alcanzar. Hasta recientemente, sin embar-

go, esos derechos no ha tenido estatuto constitucional, reconocido, al menos bajo una forma justificable que asegure el respeto de su contenido. Eso ha cambiado durante las dos últimas décadas introduciendo en las constituciones aspectos centrales de estos elementos esenciales en un Estado.

El Profesor *Michel Rosenfeld* de EE.UU. sostiene que los derechos económicos sociales están interrelacionados con el resto de los derechos individuales y que no existe diferencia entre los derechos de primera generación y los de segunda generación.

Continúa el profesor citando a Dworkin donde establece la pregunta si los derechos económicos sociales son derechos o políticas de estado, lo cual involucra problemas de tipo *definicional*. Señala la importancia de calibrar el alcance ("scope") de estos derechos, de la red de contención social, de la noción de dignidad humana (siguiendo a los autores alemanes) y a los problemas de implementación a través de las respectivas agencias estatales. Los derechos son recursos y garantías y las políticas con fines colectivos u objetivos colectivos. En los derechos de primera generación no interviene el Estado, derechos individuales; los derechos de segunda generación sí interviene el Estado: son los derechos sociales positivos.

Por lo tanto los derechos económicos sociales y culturales no son derechos políticos sino son derechos autónomos positivos.

En este rubro, también se debatió sobre la vinculación entre "Derechos" y "Democracia". En algún caso se hacía hincapié (tesis *fundamentalista*) en que la asignación mínima de derechos sociales y económicos era un "presupuesto" del funcionamiento de un sistema democrático y que en consecuencia su consecución era imperativa y no podía ser condicionada o menoscabada por las autoridades elegidas. Por otro lado, también se indicaba (tesis *relativista*) que la asignación de los derechos era un "producto" del sistema democrático y que los jueces debían ser deferentes a las decisiones de las autoridades competentes habida cuenta la inevitable insuficiencia de los recursos para atender y satisfacer las posiciones maximalistas.

5. LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS Y PUEBLOS INDÍGENAS

Los derechos de las minorías pueden variar según los Estados y, algunas veces, entre las minorías mismas. Potencialmente, sin embargo, ellos incluyen derechos y libertades políticas, civiles y culturales; pueden aplicarse a grupos minoritarios colectivamente o a los individuos que forman parte de ellos; se hallan en situación de exigir una acción positiva del Estado, y también permitir una acción estatal positiva.

No fue sorprendente que hubiera pocos puntos compartidos en las ponencias dedicadas a los problemas de las Minorías y Pueblos Indígenas, en las relativas al Derecho a la Autodeterminación, y en las relativas a la Descentralización y Democracia local. En estos tópicos se discrepaba ya desde la

premisa valorativa, puesto que estos fenómenos eran vistos alternativamente como una "aspiración" a conquistar por la sociedad o como una "amenaza" al poder ordenatorio del Estado. Semejante desacuerdo hacía muy difícil avanzar hacia un análisis objetivado de los conceptos y de los institutos jurídicos; a lo cual se unía la corroboración de que estos asuntos revisten carices sumamente diferenciales en cada caso y son reacios a una teoría general.

6. FEDERALISMO. ¿DERECHO CONSTITUCIONAL SUBNACIONAL O DE LA DESCENTRALIZACIÓN? (1)

Durante el transcurso del VII Congreso Mundial de Derecho Constitucional celebrado en Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio del 2007, se abordó la temática del llamado "derecho constitucional subnacional" (Taller núm. 11, 13 de junio, 9,30 a 12,30 horas, Aula 5 del "Zappeion Megaron").

Allí pudo palpase en concreto la riqueza y variedad de casos que hoy registra el derecho constitucional de la descentralización. En efecto, el panel, presidido por los Profesores Bob Williams y A. Hernández, escuchó ponencias e intervenciones de expertos sobre Estados Unidos, Brasil, España, Cataluña (así es, desgajada de la anterior), Hong Kong, Canadá (especialmente, Québec), Sudán, Bélgica, Australia, Gran Bretaña, Alemania, entre otras.

De mucho interés, fueron las observaciones introductorias del Profesor Alan Tarr, de la Universidad de Rutgers, quien marcó los problemas relativos al "espacio constitucional" (lo que en nuestro clásico derecho político vendría a ser "el territorio como elemento del Estado"). Los profesores Christina Murray (Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica) y B. Williamson (Wisconsin, Estados Unidos) pintaron un muy interesante cuadro del federalismo en el Sudán, fruto de un serio trabajo de campo allí realizado, y que demuestra que ese país es más que la guerra fratricida de Darfur. El caso español volvió a demostrar que el tema de las comunidades autónomas del Título VIII de la Constitución de 1978, lejos está de encontrarse medianamente resuelto.

Dos participaciones de Estados Unidos fueron particularmente relevantes. El profesor John Dinan (Wake Forest University, North Carolina), se interrogó cuándo sabemos que estamos frente a una constitución subnacional, y si la expresión no debería ser sustituida por la de gobiernos subnacionales. En una línea más escéptica, James Gardner (SUNY, de Buffalo), en su brillante cierre cuestionó la propia existencia de un "constitucionalismo subnacional". Desde su perspectiva, una constitución es un "outcome" (resultado) que depende de los diversos contextos en los que funciona.

Walter Carnota entendió que el problema en materia de protección de derechos fundamentales a cargo de entidades subnacionales no se da tanto

(1) CARNOTA, WALTER F., "El Estado del federalismo en el mundo según el Congreso Mundial de Derecho Constitucional de Atenas", www.eldial.com, DCBAI.

cuando la tutela es igual o mayor (la famosa "redundancia" de la que hablaba Daniel Elazar), sino en supuestos francamente regresivos, como en la limitación a la propiedad contenida en el art. 61 de la nueva Constitución de Corrientes del 10 de junio de 2007. Además, en el "espacio constitucional subnacional argentino" debe necesariamente incluirse a los municipios con arreglo a los claros términos del art. 123 CN, y asimismo prestar atención a los contenidos del art. 124 de la ley mayor. Los derechos básicos no sólo "bajan" ("trickle down") del todo federal a sus componentes, sino que también pueden "subir" ("trickle up").

La vertiginosa sesión, manejada en inglés y francés como es práctica en estos eventos (2), puso en evidencia múltiples enfoques y puntos de vista sobre el federalismo hoy, desde los más optimistas hasta los más pesimistas, y desde los localistas hasta los internacionalistas. Concluyó con la promesa de configurar un grupo de investigación sobre estos tópicos, en el marco de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, patrocinadora de estos encuentros.

7. PUNTOS DE ENCUENTROS Y REFLEXIONES FINALES

Finalmente, los puntos de consensos se han advertido que, con más o menos matices, es posible hablar de la existencia de una estructura constitucional global, basada en puntos de apoyo nominalmente claros:

- Separación de poderes,
- Ciudadanía inclusiva,
- Derechos humanos,
- Descentralización política,
- Estado de derecho, y
- Democracia.

(2) CARNOTA, WALTER, "El mundo de los constitucionalistas y los constitucionalistas del mundo", LA LEY, Columna de Opinión, 8/3/2004, p.1.

ANEXO DE JURISPRUDENCIA

~

Todos X
derecho

1. MARBURY C. MADISON

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación — Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación — Constitución Nacional — Facultades del Poder Judicial — Poder Judicial — Supremacía constitucional

Si una ley entra en conflicto con la Constitución en su aplicación al caso concreto, la Corte debe determinar cual norma gobierna la especie — cuestión esencial a la administración de justicia— debiendo inclinarse por la segunda, al ser ésta de jerarquía mayor a cualquier ley ordinaria.

SC Estados Unidos, 1803/02/24.— Marbury vs. Madison (*).

1 Cranch 137, 2 L.Ed. 60 (1803) :

Antes de transcribir la opinión de la Corte, el relator sintetizó brevemente los antecedentes del caso, del siguiente modo:

"En el último período, esto es, diciembre de 1801, William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, y William Harper, a través de su abogado Charles Lee —ex ministro de Justicia de los EE.UU.— solicitaron al Tribunal que ordenara a James Madison manifestar las causas por las cuales la Corte debería abstenerse de exigirle la entrega de los nombramientos a los demandantes donde se los designaba jueces de paz del Distrito de Columbia. Esta petición fue apoyada en testimonios (incluyendo uno del hermano de John Marshall —James—) de los siguientes hechos: que el señor Madison estaba enterado de esta petición y que el señor Adams, ex presidente de los EE.UU., elevó al Senado las nominaciones de los candidatos para ser de-

signados en tales cargos; que el Senado aconsejó y consintió estas designaciones; que las correspondientes designaciones formales nombrándolos jueces fueron firmadas por el presidente y, finalmente, que el sello de los EE.UU. estaba puesto en debida forma en tales designaciones por el entonces secretario de Estado (John Marshall); que los solicitantes habían pedido al señor Madison les entregara tales nombramientos con resultado negativo y que dichas designaciones les fueran retenidas.

Sobre estas bases, fue emitida una orden para que el secretario de Estado diera cuenta de las causas que motivaron su conducta".

Posteriormente, el 24 de febrero de 1803, la Corte emitió la siguiente opinión conducida por el voto del presidente John Marshall:

"Durante el último período la Corte expidió una orden para que el secretario de Estado exhibiera los motivos por los cuales se le denegaba a William Marbury la entrega de su designación como juez de paz del Condado de Washington, Distrito de Columbia. No se han dado razones de tal proceder y, ahora, la petición se dirige a obtener de la Corte un mandamiento que haga efectiva la entrega de dichos nombramientos.

Lo particularmente delicado de este caso, la novedad de algunas de sus circunstancias, y la verdadera dificultad que encierran los puntos contenidos en el mismo, requieren una exposición completa de los fundamentos que sostienen la opinión que dará esta Corte.

Según el orden seguido en el análisis del caso, la Corte ha considerado y decidido las siguientes cuestiones:

(*) Publicado en: Colección de Análisis Jurisprudencial Teoría General del Derecho - Director: Eduardo Angel Russo - Editorial LA LEY, 2002, 3, con nota de Sergio Gustavo Simona - Gelli, Miller, Cayuso en Constitución y Poder Político Tomo 1, 5, Ed. Astrea.

1) ¿Tiene el solicitante derecho al nombramiento que demanda?

2) Si lo tiene, y si ese derecho ha sido violado, ¿proveen las leyes del país un remedio a esa violación?

3) Si lo proveen, ¿es dicho remedio un mandamiento que corresponda a esta Corte emitir?

La primera cuestión es: ¿Tiene el solicitante derecho al nombramiento que demanda?

Es decididamente la opinión de esta Corte que, cuando un nombramiento ha sido firmado por el presidente la designación debe considerarse hecha; y que la misma es completa cuando tiene el sello de los EE.UU. puesto por el secretario de Estado.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que su nombramiento fue firmado por el presidente y sellado por el secretario de Estado, el señor William Marbury está designado; y como la ley que crea el cargo dio al funcionario (Marbury) el derecho de ejercerlo por cinco años, en forma independiente del Ejecutivo, el nombramiento es irrevocable por conferir al funcionario designado derechos legítimos que están protegidos por las leyes de su país.

La retención de su nombramiento, es por lo tanto, un acto que la Corte considera no respaldado por la ley y por ello violatorio de legítimos derechos adquiridos.

Esto nos conduce a la segunda cuestión: Si el derecho existe y ha sido violado, ¿proveen las leyes del país un remedio a esa violación?

La esencia misma de la libertad civil consiste, ciertamente, en el derecho de todo individuo a reclamar la protección de las leyes cuando ha sido objeto de un daño.

Uno de los principales deberes de un gobierno es proveer esta protección.

El gobierno de los EE.UU. ha sido enfáticamente llamado un gobierno de leyes y no de hombres. Tal gobierno, ciertamente, dejaría de merecer ese alto calificativo si las leyes no brindarían modos de reparar la violación de un derecho legítimamente adquirido.

Si tal cosa fuera a suceder en la jurisprudencia de nuestro país, ello sólo podría deberse a las especiales características del caso.

Nos corresponde, por lo tanto, preguntarnos si existe en este caso algún ingrediente que lo exima de investigaciones o que prive a la parte perjudicada de reparación legal. ¿Está dicho elemento presente en el caso? ¿Constituye —el acto de entregar o retener

una designación escrita— un mero acto político reservado al Departamento Ejecutivo para cuyo cumplimiento nuestra Constitución ha depositado la total confianza en el Ejecutivo supremo, de modo que cualquier conducta desajustada a su respecto no tenga prevista la consecuente reparación para el caso que dañe a un individuo?

Sin duda, tales casos pueden existir. Pero que cada deber asignado a algunos de los grandes departamentos del Poder Ejecutivo constituya uno de estos casos es, sin duda, inadmisibles.

De ello se sigue, por lo tanto, que el examen de la legalidad de los actos de los titulares de las reparticiones dependientes del Ejecutivo, depende —en cada caso— de la naturaleza del acto.

Por la Constitución de los EE.UU., el presidente está investido de algunos importantes poderes políticos cuyo ejercicio está librado a su exclusivo arbitrio, y por el cual es sólo responsable ante el pueblo, desde el punto de vista político, y ante su propia conciencia.

Para colaborar con él en el cumplimiento de sus funciones, puede designar funcionarios que actúen bajo su autoridad y de conformidad con sus órdenes. En estos casos, los actos de los funcionarios son los actos del presidente, y sea cual fuere la opinión que pueda merecer el modo en que el Ejecutivo utiliza sus poderes discrecionales, no existe ni puede existir poder alguno que los controle. Las materias son políticas, atañen a la Nación, no a derechos individuales, y habiendo sido confiadas al Ejecutivo, la decisión del Ejecutivo es terminante.

Lo dicho está claramente ejemplificado en la creación legislativa del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores debe desempeñarse, desde que su función es creación legislativa, precisamente de conformidad con la voluntad del presidente. Es meramente el órgano a través del cual se transmite la voluntad del presidente. Los actos de ese funcionario, en su calidad de tal, no pueden ser nunca examinados por los tribunales.

Pero cuando el Congreso impone a ese funcionario otras obligaciones; cuando se le encomienda por ley llevar a cabo ciertos actos; cuando los derechos de los individuos dependen del cumplimiento de tales actos, ese funcionario deja de ser funcionario del presidente para convertirse en funcionario de la ley; es responsable ante las leyes por su

conducta y no puede desconocer a su discreción los derechos adquiridos de otros.

La conclusión de este razonamiento es que cuando los titulares de los departamentos actúan como agentes políticos o confidenciales del Ejecutivo y no hacen más que poner en práctica la voluntad del presidente —en aquellos casos en que éste posee poderes discrecionales legal o constitucionalmente conferidos—, nada puede resultar más claro que el control de tales actos sólo puede ser político. Pero cuando se les asigna por ley una obligación determinada de cuyo cumplimiento depende la vigencia de derechos individuales, parece igualmente claro que todo aquel que se considere perjudicado por el incumplimiento de tal clase de obligaciones tiene derecho a recurrir a las leyes de su país para obtener una reparación. Es por lo tanto la opinión de esta Corte que Marbury tiene derecho a su nombramiento y que la negativa a entregárselo constituye una clara violación de ese derecho frente a la cual las leyes de su país brindan un remedio.

Resta considerar ¿le corresponde el remedio que solicita? Ello depende de: a) la naturaleza de la medida que solicita, y b) el poder de esta Corte.

Si la medida solicitada fuera concedida, debería dirigirse a un funcionario del gobierno, y el contenido de la misma consistiría, usando las palabras de Blackstone, en 'una orden de hacer algo en particular allí especificado, que atañe a su cargo y deberes y que la Corte ha determinado previamente, o al menos, supuesto, que es correcto y ajustado a derecho'. O bien, en las palabras de Lord Mansfield, el solicitante, en este caso, tiene 'un derecho a ejecutar un cargo de interés público, y es privado de la posesión de ese derecho'. Estas circunstancias ciertamente se dan en este caso.

Pero para que el mandamiento —la medida solicitada— surta los efectos deseados, debe ser enviada a un funcionario al cual pueda serle dirigida, sobre la base de los principios legales; y la persona solicitante de la medida debe carecer de otro recurso legal específico.

Respecto del funcionario al cual se dirigiría la medida, la íntima relación política que existe entre el presidente de los EE.UU. y los titulares de los ministerios hace particularmente fastidiosa y delicada cualquier investigación legal de sus actos, y hasta puede dudarse de que corresponda llevar a cabo tales investigaciones. Es común que la gente en ge-

neral no reflexione ni examine a fondo las impresiones que recibe y, desde tal punto de vista, no sería conveniente que en un caso como éste se interprete la atención judicial del reclamo de un particular como una forma de intromisión en la esfera de prerrogativas exclusivas del Poder Ejecutivo.

No es necesario que la Corte renuncie a toda su jurisdicción sobre tales asuntos. Nadie sostendría tan absurda y excesiva extravagancia ni por un momento. La competencia de la Corte consiste, únicamente, en decidir acerca de los derechos de los individuos y no en controlar el cumplimiento de los poderes discrecionales del presidente o sus ministros. Los asuntos, que por su naturaleza política o por disposición constitucional o legal, están reservados a la decisión del Ejecutivo, no pueden ser sometidos a la opinión de la Corte.

Pero si no se tratara de un asunto de tal naturaleza; si, lejos de constituir una intrusión en los asuntos propios del gabinete, estuviera únicamente vinculado con un papel cuya obtención la ley permite sólo a condición del pago de 10 centavos; si ello no supusiera intromisión alguna en materias sobre las cuales se considera al Ejecutivo como no sujeto a control alguno; ¿qué habría en la alta condición del funcionario que impidiera a un ciudadano reclamar sus derechos ante un tribunal de justicia, o que prohibiera a éste atender el reclamo, o expedir una orden mandando el cumplimiento de una obligación no dependiente de los poderes discrecionales del Ejecutivo, sino de actos particulares del Congreso y de los principios generales del derecho?

Si uno de los titulares de los departamentos de Estado comete un acto ilegal amparándose en su cargo, dando lugar a un reclamo de un ciudadano afectado, no puede sostenerse que su cargo, por sí solo, lo exima de ser juzgado por el procedimiento ordinario y obligado a obedecer el juicio de la ley. ¿Cómo podría entonces su cargo exceptuarlo de la aplicación de este modo particular de decidir acerca de la legalidad de su conducta si el caso no reviste diferencia alguna con cualquier otro en el cual un individuo común sería procesado?

No es por el cargo que tenga la persona sino por la naturaleza de aquello que se le ordena hacer que se juzgará la pertinencia del mandamiento. Cuando un ministro actúa en un caso en que se ejercen los poderes discrecionales del Ejecutivo y donde el funcionario

259

actúa como mero órgano de la voluntad del presidente, correspondería rechazar sin la menor duda todo pedido a la Corte para que ejerza un control de tal conducta a cualquier respecto. Pero cuando la conducta del funcionario es encomendada por la ley —de modo tal que su cumplimiento o incumplimiento afecte los derechos absolutos de los individuos— la cual no se encuentra bajo la dirección del presidente y no puede presumirse que éste la haya prohibido, como por ejemplo registrar un nombramiento o un título de propiedad que ha cumplido todas las formalidades de la ley, o entregar una copia de tales registros; en esos casos, no se advierte sobre qué bases los tribunales de la Nación podrán estar menos obligados a dictar sentencia que si se tratara de funciones atribuidas a otro individuo que no fuese ministro.

Este, por lo tanto, es un claro caso en el que corresponde emitir un mandamiento, sea de entrega de la designación o de una copia de la misma extraída de los registros correspondientes, quedando entonces, por resolver, una sola cuestión: ¿puede la Corte emitir ese mandamiento?

La ley por la que se establecen los tribunales judiciales en los EE.UU. autoriza a la Corte Suprema a emitir 'mandamientos, en casos en que fuesen comprendidos según los principios y las costumbres del derecho, a cualquier tribunal o persona designado en su oficio bajo la autoridad de los EE.UU. (1).

(1) El texto completo de la sección 13 de la ley de organización de la justicia de 1789 (Judiciary Act of 1789): "y promúlguese, que la Corte Suprema tendrá jurisdicción exclusiva en todas las controversias de naturaleza civil en las que un estado fuere parte, salvo entre un estado y sus ciudadanos; y salvo también entre un estado y ciudadanos de otros estados o extranjeros, en cuyo caso tendrá jurisdicción originaria pero no exclusiva. Ejercerá también jurisdicción exclusiva en todo juicio o procedimiento contra embajadores, otros ministros públicos, miembros de su familia o sus empleados domésticos, siempre que pueda intervenir como tribunal de justicia conforme con el derecho internacional; y tendrá jurisdicción originaria pero no exclusiva en todas aquellas causas iniciadas por embajadores, u otros ministros públicos, o aquellas en las que un cónsul, o vicedcónsul, fuere parte. El juzgamiento de cuestiones de hecho ante la Corte Suprema en todas las causas contra ciudadanos de los EE.UU., se llevará a cabo por jurados. La Corte Suprema también tendrá jurisdicción por apelación de los tribunales de circuito y las cortes de los estados, y en los casos específicamente mencionados aquí; y tendrán el poder de mandar órdenes a los tribunales de almirantazgo, y mandamientos, en casos en que fuesen comprendidos según los principios y las costumbres del derecho, a cualquier tribunal o persona designado en su oficio bajo la autoridad de los EE.UU."

Siendo el secretario de Estado un funcionario bajo la autoridad del gobierno de los EE.UU., se encuentra precisamente comprendido en las previsiones de la ley precitada; y si esta Corte no está autorizada a emitir una orden de ejecución a tal funcionario, sólo puede ser a causa de la inconstitucionalidad de la ley, incapaz, por ello, de conferir la autoridad y de asignar las obligaciones que sus palabras parecen conferir y asignar. La Constitución deposita la totalidad del Poder Judicial de los EE.UU. en una Corte Suprema y en tantos tribunales inferiores como el Congreso establezca en el transcurso del tiempo. Este poder se extiende expresamente al conocimiento de todas las causas que versen sobre puntos regidos por las leyes de los EE.UU. y, consecuentemente, de algún modo puede extenderse al presente caso ya que el derecho invocado deriva de una ley de los EE.UU. Al distribuir este poder la Constitución dice: 'En todos los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la Corte Suprema ejercerá jurisdicción originaria. En todos los casos mencionados anteriormente, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación' (2).

Se ha sostenido ante el Tribunal que, como el otorgamiento constitucional de jurisdicción a la Corte Suprema y a los tribunales ordinarios es general, y la cláusula que asigna

(2) El texto completo del art. 3º de la Constitución de los EE.UU. es el siguiente:

"Sección I. El Poder Judicial de los EE.UU. será atribuido a una Corte Suprema y a tantos tribunales inferiores como el Congreso decidiere autorizar y establecer. Los jueces, tanto de la Corte Suprema como de los tribunales inferiores, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán, en plazos fijos, una compensación por sus servicios que no podrá ser disminuida mientras permanecieren en sus funciones.

Sección II. Corresponde al Poder Judicial aplicar el derecho positivo y los principios de justicia, en todas las causas que versaren sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de los EE.UU., y por lo tratados hechos o que fueren hechos bajo su autoridad; de todas las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más estados; entre un estado y los vecinos de otro; entre los vecinos de diferentes estados; y entre ciudadanos del mismo estado que demandaren tierras concedidas por diferentes estados; y entre una provincia, o sus vecinos, contra un estado o ciudadano extranjero.

En todos los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la Corte Suprema ejercerá jurisdicción originaria. En todos los casos mencionados anteriormente, la Corte Suprema ejercerá jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso."

las causas de jurisdicción originaria a la Corte Suprema no contiene expresiones negativas o restrictivas, el Poder Legislativo mantiene la facultad de atribuir competencia originaria a la Corte en otros casos que los precedentemente indicados, tomando en cuenta que tales casos pertenecen al Poder Judicial de los Estados Unidos.

Si se hubiera querido dejar librado a la discreción del Poder Legislativo la posibilidad de distribuir el Poder Judicial entre la Corte Suprema y los tribunales inferiores, habría sido ciertamente inútil hacer otra cosa que definir el ámbito de competencia del Poder Judicial en general, mencionando los tribunales a los que corresponde ejercerlo. Si ésta es la interpretación correcta, el resto de la norma constitucional carece de sentido.

Si el Congreso tiene la libertad de asignar a esta Corte competencia por apelación en los casos en los que la Constitución le asigna competencia originaria y fijarle competencia originaria en los casos en que le corresponde ejercerla por apelación, la distribución hecha en la Constitución es forma carente de contenido.

Las palabras afirmativas son, a menudo en su operatividad, negatorias de otros objetos que los prescriptos, y en este caso debe asignárseles ese sentido o pena de privarlas de sentido en absoluto.

No puede presumirse que cláusula alguna de la Constitución esté pensada para no tener efecto, y, por lo tanto, la interpretación contraria es inadmisiblesalvo que el texto expreso de la Constitución así lo manifieste. Cuando un instrumento legal organiza las bases fundamentales de un sistema judicial dividiéndolo en una Corte Suprema y en tantas inferiores como el Congreso decida, enumerando sus poderes y distribuyéndolos mediante la delimitación de los casos en los que la Corte Suprema ejercerá jurisdicción originaria y aquellos en que la ejercerá por vía de apelación, el sentido evidente de las palabras parece ser que en una clase de casos la competencia será originaria y no en los demás. Si cualquier otra interpretación convirtiera en inoperante dicha cláusula, tendríamos allí una razón adicional para rechazarla y para adherir al sentido obvio de las palabras. Luego, para que esta Corte esté en condiciones de emitir una orden de ejecución como la que se pide, debe demostrarse que se trata de un caso de competencia por apelación.

Se ha dicho en el Tribunal que la jurisdicción apelada puede ejercerse de diversos

modos y que siendo la voluntad del Congreso que un mandamiento pueda ser emitido en el ejercicio de la jurisdicción apelada (ver ley de organización judicial de los EE.UU. de 1789), dicha voluntad debe ser obedecida. Esto es cierto, pero no obstante ello, la jurisdicción debe ser apelada y no originaria.

Es el criterio esencial de la jurisdicción por apelación, que ella abarca tópicos previamente determinados y no crea otros nuevos. Por ello, aunque es posible emitir un mandamiento a los tribunales inferiores, hacerlo respecto de un funcionario para que entregue un documento es lo mismo que intentar una acción originaria para la obtención de dicho documento, y por ello, no parece pertenecer a la jurisdicción apelada sino a la originaria. Tampoco es necesario en este caso, capacitar a la Corte para que ejerza su competencia por vía de apelación. Por lo tanto, la autoridad otorgada a la Corte Suprema por la ley de organización judicial de los EE.UU. para emitir órdenes directas de ejecución de conductas a funcionarios públicos, no parece estar respaldada en la Constitución, y hasta se hace necesario preguntarse si una competencia así conferida puede ser ejercida.

La pregunta acerca de si una ley contraria a la Constitución puede convertirse en ley vigente del país es profundamente interesante para los EE.UU. pero, felizmente, no tan complicada como interesante. Para decidir esta cuestión parece necesario tan sólo reconocer ciertos principios que se suponen establecidos como resultado de una prolongada y serena elaboración. Todas las instituciones fundamentales del país se basan en la creencia de que el pueblo tiene el derecho preexistente de establecer para su gobierno futuro los principios que juzgue más adecuados a su propia felicidad. El ejercicio de ese derecho supone un gran esfuerzo, que no puede ni debe ser repetido con mucha frecuencia. Los principios así establecidos son considerados fundamentales. Y desde que la autoridad de la cual proceden es suprema, y puede raramente manifestarse, están destinados a ser permanentes. Esta voluntad originaria y suprema organiza el gobierno y asigna a los diversos poderes sus funciones específicas. Puede hacer sólo esto, o bien fijar, además, límites que no podrán ser transpuestos por tales poderes.

El gobierno de los EE.UU. es de esta última clase. Los poderes de la legislatura están definidos y limitados. Y para que estos límites no se confundan u olviden, la Constitución es

escrita. ¿Con qué objeto son limitados los poderes y a qué efectos se establece que tal limitación sea escrita si ella puede, en cualquier momento, ser dejada de lado por los mismos que resultan sujetos pasivos de la limitación?

Si tales límites no restringen a quienes están alcanzados por ellos y no hay diferencia entre actos prohibidos y actos permitidos, la distinción entre gobierno limitado y gobierno ilimitado queda abolida.

Hay sólo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza.

Ciertamente, todos aquellos que han elaborado constituciones escritas las consideran la ley fundamental y suprema de la Nación, y, consecuentemente, la teoría de cualquier gobierno de ese tipo debe ser que una ley repugnante a la Constitución es nula. Esta teoría está íntimamente ligada al tipo de Constitución escrita y debe, por ello, ser considerada por esta Corte como uno de los principios básicos de nuestra sociedad. Por ello esta circunstancia no debe perderse de vista en el tratamiento ulterior de la materia.

Si una ley contraria a la Constitución es nula, ¿obliga a los tribunales a aplicarla no obstante su invalidez? O bien, en otras palabras, no siendo ley, ¿constituye una norma operativa como lo sería una ley válida? Ello anularía en la práctica lo que se estableció en la teoría y constituiría, a primera vista, un absurdo demasiado grueso para insistir en él. Sin embargo la cuestión merece recibir un atento tratamiento.

Si lugar a dudas, la competencia y la obligación del Poder Judicial es decidir qué es ley. Los que aplican las normas a casos particulares deben por necesidad exponer e interpretar esa norma. Si dos leyes entran en conflicto entre sí el tribunal debe decidir acerca de la validez y aplicabilidad de cada una. Del

mismo modo cuando una ley está en conflicto con la Constitución y ambas son aplicables a un caso, de modo que la Corte debe decidirlo conforme a la ley desechando la Constitución, o conforme a la Constitución desechando la ley, la Corte debe determinar cuál de las normas en conflicto gobierna el caso. Esto constituye la esencia misma del deber de administrar justicia. Luego, si los tribunales deben tener en cuenta la Constitución y ella es superior a cualquier ley ordinaria, es la Constitución, y no la ley la que debe regir el caso al cual ambas normas se refieren.

Quienes niegan el principio de que la Corte debe considerar la Constitución como la ley suprema, se ven reducidos a la necesidad de sostener que los tribunales deben cerrar los ojos a la Constitución y mirar sólo a la ley. Esta doctrina subvertiría los fundamentos mismos de toda constitución escrita. Equivaldría a declarar que una ley totalmente nula conforme a los principios y teorías de nuestro gobierno es, en la práctica, completamente obligatoria. Significaría sostener que si el Congreso actúa de un modo que le está expresamente prohibido la ley así sancionada sería, no obstante tal prohibición, eficaz. Estaría confiriendo práctica y realmente al Congreso una omnipotencia total con el mismo aliento con el cual profesa la restricción de sus poderes dentro de límites estrechos. Equivaldría a establecer al mismo tiempo los límites y el poder de transgredirlos a discreción.

Reducir de esta manera a la nada lo que hemos considerado el más grande de los logros en materia de instituciones políticas —una constitución escrita— sería por sí mismo suficiente en América, donde las constituciones escritas han sido vistas con tanta reverencia, para rechazar la tesis. Pero las manifestaciones particulares que contiene la Constitución de los EE.UU. construyen un andamiaje de argumentos adicionales en favor del rechazo de esta interpretación.

El Poder Judicial de los EE.UU. entiende en todos los casos que versen sobre puntos regidos por la Constitución.

¿Pudo, acaso, haber sido la intención de quienes concedieron este poder, afirmar que al usar la Constitución, no debería atenderse a su contenido? ¿Que un caso regido por la Constitución debiera decidirse sin examinar el instrumento que lo rige?

Esto es demasiado extravagante para ser sostenido.

En ciertos casos, la Constitución debe ser interpretada y analizada su contenido por parte de los jueces.

Y si de este modo los jueces pueden abrir y examinar la totalidad de la Constitución ¿qué parte de ella les está prohibido leer u obedecer?

Hay muchas otras partes de la Constitución que ilustran esta materia. Dice la Constitución que: 'ningún impuesto o carga se impondrá sobre artículos exportados desde cualquiera de los estados'. Supongamos una carga impuesta sobre la exportación de algodón, o tabaco o harina, y supongamos que se promueve una acción judicial destinada a exigir la devolución de lo pagado en virtud de dicha carga.

¿Debe darse un pronunciamiento judicial en tal caso? ¿Deben los jueces cerrar los ojos a la Constitución y ver sólo la ley?

La Constitución prescribe que: 'No se sancionarán leyes conteniendo condenas penales individualizadas ni leyes retroactivas'.

Si, no obstante, tales leyes son sancionadas y una persona es procesada bajo tales leyes ¿debe la Corte condenar a muerte a esas víctimas a quienes la Constitución manda proteger?

Dice la Constitución: 'Ninguna persona será procesada por traición salvo mediante el testimonio de dos testigos sobre el mismo acto o mediante su confesión pública ante un tribunal de justicia'.

En este caso, el lenguaje de la Constitución está especialmente dirigido a los tribunales. Les prescribe directamente una regla de prueba de la que no pueden apartarse.

Si la Legislatura modificara esa norma y permitiera la declaración de un solo testigo o la confesión fuera de un tribunal de justicia como requisitos suficientes de prueba, ¿debería la norma constitucional ceder frente a esa ley?

Mediante estos y muchos otros artículos que podrían seleccionarse es claro que los constituyentes elaboraron ese instrumento como una regla obligatoria tanto para los tribunales como para la Legislatura.

¿Por qué motivo, si no, prescribe a los jueces jurar su cumplimiento? Este juramento apela, ciertamente, a su conducta en el desempeño de su cargo de carácter oficial.

¿Qué inmoralidad sería imponérselos, si ellos (los jueces) fueran a ser usados como instrumentos —y como instrumentos conscientes— de la violación de lo que juran respetar!

El juramento del cargo judicial impuesto por el Congreso, es también completamente ilustrativo de la opinión legislativa sobre esta cuestión.

Este juramento dice: 'juro solemnemente que administraré justicia sin importar las personas y haré justicia igualmente al pobre como al rico; y que desempeñaré leal e imparcialmente todas las obligaciones atinentes a mi cargo como... de acuerdo a mis mejores capacidades y comprensión, conforme con la Constitución y las leyes de los EE.UU.'.

¿Por qué motivo jura un juez desempeñar sus deberes de acuerdo con la Constitución de los EE.UU. si esa Constitución no fuera una norma obligatoria para su gobierno? ¿Si estuviere cerrada sobre él y no pudiera ser inspeccionada por él?

Si fuera ése el estado real de las cosas, constituiría algo peor que una solemne burla.

Pero además de ello, imponer, tanto como jurar en esos términos sería una hipocresía.

No es tampoco inútil observar que, al declarar cuál será la ley suprema del país, la Constitución en sí misma es mencionada en primer lugar; y no todas las leyes de los EE.UU. tienen esta calidad, sino sólo aquellas que se hagan de conformidad con la Constitución.

De tal modo, la terminología especial de la Constitución de los EE.UU. confirma y enfatiza el principio, que se supone esencial para toda constitución escrita, de que la ley repugnante a la Constitución es nula, y que los tribunales, así como los demás poderes, están obligados por ese instrumento.

Por ello, se rechaza la petición del demandante. Cúmplase".

256

2. SIRI, ANGEL S.

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Amparo de la libertad

La comprobación inmediata de que una libertad constitucional se halla evidentemente restringida, sin orden de autoridad competente ni expresión de causa que la justifique, es suficiente para que la garantía constitucional invocada sea restablecida por el Poder Judicial en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que reglamente dicha garantía; por cuanto las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución, e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales sólo son requeridas para establecer en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación, como dice el art. 18 de la Ley Suprema a propósito de una de ellas; y porque los preceptos constitucionales, tanto como la experiencia institucional del país, reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de derecho, e imponen a los jueces el deber de asegurarlas.

CS, 1957/12/27. — Siri, Angel S.

Opinión del Procurador General de la Nación.

De lo informado a fs. 37 y vta. así como de las propias manifestaciones formuladas por el interesado en su escrito de fs. 35, surge que la clausura del periódico "Mercedes", que dió origen a las presentes actuaciones, ha sido dejada sin efecto.

En consecuencia, puesto que cualquier pronunciamiento de V. E. respecto de la cuestión planteada revestiría en la actualidad el carácter de abstracto, opino que corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de fs. 46. — Agosto 13 de 1957. — *Sebastián Soler*.

Considerando: Atento el informe de fs. 59, y sin perjuicio de observar que su contenido es contradictorio con el de fs. 37 —razón por la que correspondería aclarar cuál es en definitiva la situación actual del diario "Mercedes"—, paso a dictaminar sobre el fondo del asunto.

En este aspecto, ya he tenido oportunidad en el caso de Fallos, t. 236, p. 41, de opinar que el recurso de hábeas corpus sólo protege a las

personas privadas de su libertad corporal sin orden de autoridad competente, por lo que, si V.E. decide admitir la procedencia del recurso intentado, estimo que correspondería confirmar lo resuelto en cuanto ha podido ser materia de apelación extraordinaria. — Octubre 14 de 1957. — *Sebastián Soler*.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1957.

Considerando: Que en los autos "Siri, Angel, s./interpone recurso de hábeas corpus", en los que a fs. 47 vta. se ha concedido el recurso extraordinario contra la sentencia de la Cám. de Apel. en lo Penal del departamento de Mercedes (Prov. de Buenos Aires), manifestando que el diario "Mercedes", de su propiedad y administración, continuaba clausurado desde comienzos de 1956, "mediante custodia provincial en el local del mismo", lo que vulneraba la libertad de imprenta y de trabajo que consagran los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional (1) y los arts. 9º, 11, 13, 14 y 23 y demás de la Constitución de la provincia. Solicitó que, previo informe del comisario de policía del partido de Mercedes sobre los motivos actuales de la custodia del local del diario, se proveyera lo que correspondía conforme a derecho y de acuerdo con las cláusulas constitucionales citadas.

Que requerido dicho informe por el juez actuante el comisario de policía informó que "con motivo de una orden recibida de la Dir. de Seguridad de esta policía, con fecha 21 de enero ppdo., al mismo tiempo que se procedió a la detención de Angel Siri, director-proprietario del diario "Mercedes", se cumplió con la clausura del local donde se imprimía el mismo, el que desde aquella fecha viene siendo custodiado por una consigna policial colocada al efecto".

Que ante la falta de especificación sobre los motivos de la clausura del diario, el juez requirió sucesivamente informe del Jefe de policía de la Prov. de Buenos Aires y del Ministerio de Gobierno de dicha provincia, todos los cuales manifiestan ignorar las causas de la clausura y la autoridad que la dispuso. Reiterada por el solicitante la declaración pedida al comienzo de estas actuaciones, el juez resolvió no hacer lugar a ella en razón de no tratarse en el caso de un recurso de hábeas corpus, el cual sólo protege la libertad física o corporal de las personas.

257

Que el solicitante interpuso recurso de revocatoria, y en subsidio el de apelación, en cuya oportunidad el juez dispuso requerir nuevo informe del comisario de policía sobre si el local del diario "aún continúa con custodia policial", informando este funcionario que desde el 29 de abril fué dejada sin efecto la consigna y se vigila el local mediante recorridos que efectúa el personal de servicio de calle". En mérito de este informe, el juez no hizo lugar a la revocatoria pedida, en consideración a que "carece de actualidad y fundamento el presente recurso de amparo, ya que no existe restricción alguna que afecte al recurrente"; y concedió el recurso de apelación para ante el superior. La Cám. de Apel. en lo Penal de Mercedes confirmó, por sus propios fundamentos, la decisión apelada.

Que contra esta sentencia el solicitante ha deducido el presente recurso extraordinario, fundado en la supuesta violación de las garantías constitucionales que invocó en su escrito originario, el cual le ha sido concedido por la Cám. de Apelación.

Que, radicada la causa ante esta Corte Suprema y con el objeto de actualizar los elementos de hecho, el tribunal requirió del juez en lo penal de Mercedes informe sobre si subsistía en la actualidad la clausura del diario, respondiendo el comisario de la localidad, en oficio dirigido al juez comisionado, que si subsistía esa clausura.

Que según resulta de los antecedentes antes relacionados, no existe constancia cierta de cuál sea la autoridad que ha dispuesto la clausura del diario ni cuáles son, tampoco, los motivos determinantes de ella. En estas condiciones, es manifiesto que el derecho que invoca el solicitante de publicar y administrar el diario debe ser mantenido.

Que, por otra parte, en sus diversos escritos el compareciente no ha dicho que interponga el recurso de hábeas corpus —como lo hace notar, además, en el escrito de fs. 40—, por lo que es erróneo el único fundamento de la sentencia denegatoria de fs. 33, confirmada con el mismo fundamento por la Cám. de Apelación, que da origen a este recurso. El escrito de fs. 1 sólo ha invocado la garantía de la libertad de imprenta y de trabajo que aseguran los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional, la que, en las condiciones acreditadas en la causa, se halla evidentemente restringida sin orden de autoridad competente y sin expresión de causa que justifique dicha restricción.

Que basta esta comprobación inmediata para que la garantía constitucional invocada

sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales sólo son requeridas para establecer "en qué caso y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación", como dice el art. 18 de la Constitución a propósito de una de ellas. Ya a fines del siglo pasado señalaba Joaquín V. González: "No son, como puede creerse, las "declaraciones, derecho y garantías", simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina" ("Manual de la Constitución Argentina", en "Obras completas", vol. 3, Buenos Aires, 1935, núm. 82; confr., además, núms. 89 y 90).

Que en consideración al carácter y jerarquía de los principios de la Carta fundamental relacionados con los derechos individuales, esta Corte Suprema, en su actual composición y en la primera oportunidad en que debe pronunciarse sobre el punto, se aparta así de la doctrina tradicionalmente declarada por el tribunal en cuanto relegaba al trámite de los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales la protección de las garantías no comprendidas estrictamente en el hábeas corpus (Fallos, t. 168, p. 15; t. 169, p. 103 y los posteriores). Los preceptos constitucionales tanto como la experiencia institucional del país reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de derecho e imponen a los jueces el deber de asegurarlas.

Por tanto, habiendo dictaminado el procurador general, se revoca la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que haga saber a la autoridad policial que debe hacer cesar la restricción impuesta al solicitante en su calidad de director-proprietario del diario clausurado. — *Alfredo Ormazabal*. — *Manuel J. Argañarás*. — *Enrique V. Gagli*. — *Benjamín Villegas Basavilbaso*. — En disidencia: *Carlos Herrera*.

Disidencia del doctor *Herrera*:

Omissis...

3. SAMUEL KOT S.R.L.

ACCION DE AMPARO

Derechos Humanos — Fábrica — Garantías constitucionales — Hábeas corpus — Procedimiento Tributario

1. Con respecto a la protección de la libertad corporal, la interpretación amplia es la que surge del pertinente precepto de la ley suprema: "Nadie puede ser... arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente", dice el art. 18, con fórmula muy general; lo que significa establecer que, no tratándose de esa única hipótesis estricta, toda privación ilegítima de la libertad personal, sin distinción alguna acerca de quien emana, autoriza el amparo de la Constitución. Esta amplitud del "habeas corpus" es la que corresponde a la tradición del derecho anglo-americano — fuente inmediata del nuestro, a través de la Constitución de los Estados Unidos — y si bien ha sido indebidamente restringido por la mayoría de los códigos procesales — que han tomado por "ratio" lo que era sólo "ocatio" —, es la que corresponde a la letra y al espíritu de la Constitución Argentina.
2. Las garantías constitucionales no son sino restricciones a la acción de los gobiernos, tendientes a impedir la extralimitación de los poderes públicos y han sido dadas a los particulares contra las autoridades. Caracterizar la libertad como limitación a la autoridad, significa que las acciones que el poder público emprenda llevan insita la idea de que la libertad del hombre es el presupuesto de la autoridad, lo que convierte en constitucionalmente inválido todo acto que conduzca a su aniquilamiento o desvirtuación. En suma, las garantías constitucionales para cuyo resguardo puede decirse que existe el remedio de amparo, son los derechos públicos subjetivos que el hombre tiene "frente al Estado" (Voto en disidencia de los doctores Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte).
3. La distinción según que la restricción ilegítima provenga de la autoridad pública o de actos de particulares no es esencial a los fines de la protección constitucional. Admitido que existe una garantía tácita o implícita que protege los diversos aspectos de la libertad individual (art. 33, Constitución Nacional), ninguna reserva cabe establecer de modo que ex-
4. Nada hay, ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución que permita afirmar que la protección de los llamados "derechos humanos" — porque son los derechos esenciales del hombre — esté circunscripta a los ataques que provengan solo de la autoridad. Nada hay tampoco que autorice la afirmación de que el ataque ilegítimo, grave y manifiesto contra cualquiera de los derechos que integran la libertad, "lato sensu", carezca de la protección constitucional adecuada que es, desde luego, la del "habeas corpus" y la de amparo, no la de los juicios ordinarios o la de los interdictos, con traslados, vistas, ofrecimiento de prueba, etc., por la sola circunstancia de que ese ataque emane de otros particulares o de grupos organizados de individuos.
5. Es verosímil presumir que en el ánimo de los constituyentes de 1853 las garantías constitucionales tuvieron, como inmediata finalidad, la protección de los derechos esenciales del individuo contra los excesos de la autoridad pública. En el tiempo en que la Constitución fue dictada, frente al individuo, sólo e inerte, no había otra amenaza verosímil e inminente que la del Estado. Pero los constituyentes tuvieron la sagacidad y la prudencia de no fijar exclusivamente en los textos sus temores concretos e históricos, sino, más bien, sus aspiraciones y sus designios permanentes y aun, eternos: "la protección de la libertad".
6. Lo que primordialmente tienen en vista el "habeas corpus" y el amparo no es el "origen" de la restricción ilegítima a cualquiera de los derechos fundamentales de la persona humana, sino estos derechos en sí mismos, a fin de que sean salvaguardados. Dichas garantías no atienden unilateralmente a los agresores, para señalar distinciones entre ellos, sino a los agredidos, para restablecer sus derechos esenciales.
7. Todo derecho del hombre muestra una configuración que podría llamarse bi-

cluya en absoluto y "a priori" toda restricción que emane de personas privadas.

fronte; uno de sus lados mira hacia el Estado y presenta al derecho revestido de la calidad de "garantía constitucional"; el otro lado, en cambio, mira hacia los terceros particulares y, desde él, el derecho es específicamente derecho privado. Cuando un particular lesiona el derecho privado de otro, su acto no es inconstitucional; tampoco vulnera garantías constitucionales, ni es susceptible del amparo que resguarda esas garantías; por el contrario, tratase de un acto ilícito y sujeto a las previsiones de la legislación ordinaria, las que deben efectivizarse de acuerdo con las normas procesales pertinentes, cuyo dictado incumbe privativamente a las provincias (Voto en disidencia de los doctores Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte).

8. No todos los derechos de que una persona puede ser titular están incluidos en el concepto jurídico de "garantía constitucional" tutelada por la acción o recurso de amparo. Para que un derecho individual revista este carácter es preciso, en principio, que se trate de un derecho público subjetivo reconocido al hombre "frente al poder público" (Voto en disidencia de los doctores Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte).
9. No es juicioso pretender que el afectado reclame la devolución de su propiedad por los procedimientos ordinarios, si cada vez que, a raíz de un conflicto laboral, muchas personas ocupan materialmente una fábrica, un instituto privado de enseñanza o cualquier otro establecimiento, los propietarios no tuvieran más recurso para defender sus derechos constitucionales, que deducir un interdicto posesorio o de despojo, con sus múltiples trámites.
10. Procede hacer lugar a la garantía constitucional del amparo interpuesta por la empresa propietaria de un establecimiento industrial ocupado ilegítimamente por su personal obrero, sin ejercer violencia alguna, a raíz de un conflicto de carácter laboral con la firma patronal; no existiendo nada que diferir a los procedimientos ordinarios establecidos por las leyes para la dilucidación de los aspectos de fondo del conflicto gremial y de los derechos de las partes, como tampoco nada que requiera ser debatido en una acción real o en un interdicto posesorio, y siendo patentes la magni-

tud del agravio y su carácter irreparable para la empresa.

11. Siempre que aparezca, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponde que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido, por la rápida vía del recurso de amparo, en tales hipótesis, los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponde resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios.
12. El amparo que la Corte Suprema ha extraído del art. 33 de la Constitución Nacional debe ser interpretado con amplitud, sin una reserva que, expresa o implícitamente, emane de los preceptos constitucionales y que imponga una inteligencia restringida del recurso de amparo, la interpretación amplia es la que mejor consulta los grandes objetivos de la ley suprema y las genuinas finalidades de aquellas garantías.

CS, 1958/09/05. — Samuel Kot S.R.L. (*)

2ª Instancia. — La Plata, julio 8 de 1958.

Que el recurso de "habeas corpus", como ha resuelto invariablemente este tribunal y lo tiene decidido la más autorizada doctrina, tiene por objeto esencial la protección de la libertad personal o corporal y no puede hacerse extensivo a la protección de otros derechos que se pretenden vulnerados. Tales derechos deben ejercitarse conforme a los respectivos procedimientos creados por las leyes de la materia (Corte Federal, Fallos: 216:606; JA, 1950-III-486, entre otros).

Siendo ello así y no encuadrando el sub júdice en ninguno de los supuestos del art. 415 del Cód. de Proced. Penal se desecha con costas la acción de amparo traída por Sabati-

(*) Publicado en: Colección de Análisis Jurisprudencial Derecho Const. - Alberto Dalla Via, 670 - Colección de Análisis Jurisprudencial Teoría Gen. del Derecho - Ricardo A. Guibourg, 308 - Colección de Análisis Jurisprudencial Derecho Const. - Daniel Alberto Sabsay, 529.

no Kot a su favor (art. 428, Cód. cit.). Prácticamente la liquidación de costas, notifíquese en el día (art. 38), agréguese por cuerda al principal y remítase al juzgado núm. 4. — Julio A. Negri. — Alejandro F. Menéndez.

Opinión del procurador general de la Nación.

El presente recurso de amparo se funda en los mismos hechos que han dado lugar a la instrucción de la causa "Houssay, Abel F. A. representando a Kot, Samuel (Soc. de Resp. Ltda.), denuncia Kot, Juan" en la que dictaminó también el día de la fecha.

Aquí, sin embargo, se hace especial hincapié en lo resuelto en Fallos: 239:459 para fundar de ese modo la intervención de los tribunales del crimen en la cuestión de que se trata, aun al margen del proceso penal antes mencionado.

Y bien, lo decidido en el recurso planteado por Angel Siri no es, a mi juicio, de aplicación al sub júdice. Allí, lo mismo que en los casos jurisprudenciales a que expresamente se refirió V. E. para destacar su apartamiento de la doctrina tradicional hasta entonces observada (Fallos: 168:15; 169:103), se pedía amparo, no contra un hecho realizado por particulares, sino contra un acto arbitrario de la autoridad para el que no existía remedio expreso en la legislación a pesar de que comportaba la violación de garantías individuales aseguradas por la Constitución.

Como se observa, pues, la situación es fundamentalmente distinta: en primer lugar, porque aquí no se trata de dejar sin efecto un acto de autoridad, puesto que los obreros ocuparon la fábrica por su propia cuenta y, en segundo término, porque al contrario de lo que ocurría en el caso citado, la legislación del Estado en cuya jurisdicción se produjo el hecho de autos prevé un remedio procesal específico para solucionar situaciones como la que se plantea en este recurso: me refiero concretamente al interdicto de recobrar o de despojo arbitrado por el art 599 del Cód. de Proced. Civil y Comercial de la Prov. de Buenos Aires a favor de quienes hayan sido despojados con violencia o clandestinidad de la posesión o tenencia de una cosa.

Por ello y sin perjuicio de señalar la confusión que derivaría de la admisión de recursos de amparo no legislados para solucionar situaciones que las normas procesales vigentes ya contemplan de modo expreso, observo que hacer lugar a la pretensión del recurrente importaría tanto, a mi juicio, como dejar implí-

tamente sin efecto una institución procesal bonaerense (la del art. 599 cit.) que no ha sido tachada en esta causa de inconstitucional.

En consecuencia, opino que corresponde desestimar el recurso del que se me ha corrido vista. — Julio 24 de 1958. — Ramón Lascano.

Buenos Aires, setiembre 5 de 1958.

La firma Samuel Kot (Soc. de Resp. Ltda.), propietaria de un establecimiento textil situado en la calle Arias 228 de Villa Lynch, partido de San Martín, Prov. de Buenos Aires, mantiene desde el 21 de marzo próximo pasado un conflicto con su personal obrero. La huelga de este personal fué primeramente declarada ilegal por la Delegación San Martín del Departamento Provincial del Trabajo con fecha 28 de marzo, por lo cual la firma patronal dispuso la concurrencia de los obreros a su trabajo dentro de las 24 horas, con excepción de los delegados Aarón Fistein y Anibal Villamayor. Un mes y medio más tarde, el presidente del Departamento Provincial del Trabajo declaró nula aquella resolución de la Delegación San Martín e intimó a ambas partes a reanudar el trabajo. La empresa se negó a reincorporar a los obreros que había despedido y entonces éstos y otros compañeros ocuparon la fábrica el día 9 de junio y se mantienen en ella hasta ahora; los patronos pueden entrar al establecimiento y sacar objetos dejando constancia escrita, mas se impide la entrada al personal de administración y a los capataces. Desde el día de la ocupación, "el establecimiento no realiza labor alguna" de suerte que "la fábrica está totalmente paralizada" (informe policial de fs. 36 del citado expediente).

El mismo día de ocupación de la fábrica, el sociogerente de la empresa, Juan Kot, formuló denuncia por usurpación ante la comisaría de Villa Lynch (San Martín) y reclamó la entrega del inmueble, iniciándose el sumario correspondiente. Estando en trámite las actuaciones fueron requeridas telefónicamente por el juez penal de La Plata —el día 16 de junio— quien, después de avocar el conocimiento del sumario, resolvió 2 días después —el 18 de junio— sobreseer definitivamente en la causa "en cuanto al hecho de la ocupación del inmueble de la calle Arias 228 de la localidad de Villa Lynch, partido de San Martín y no hacer lugar al pedido de desocupación de la misma". El fundamento de esta resolución consistió, en lo esencial, en que habiendo sido ocupado el inmueble a causa de la existencia de un conflicto colectivo de trabajo entre la mencionada empresa y su personal

obrero, "es evidente que en la especie esa ocupación no tiene por objeto el despojo de la posesión de esa cosa inmueble, con ánimo de «someterla al ejercicio de un derecho de propiedad» (art. 2351, Cód. Civil), sino que lo ha sido en función de la existencia de ese conflicto laboral".

Apelada esta resolución por el apoderado de la empresa y luego de diligenciarse algunas medidas para mejor proveer dispuestas por la Cám. 3ª de Apel. en lo Penal de La Plata, ésta "por sus fundamentos" confirmó el sobreseimiento definitivo que había sido objeto del recurso. Contra esta sentencia, el interesado dedujo recurso extraordinario el que, concedido por el tribunal ha sido declarado improcedente por esta Corte en el día de la fecha.

El mismo día de la sentencia de la cámara, pero antes de dictarse, el apoderado de la empresa se presentó ante la misma cámara deduciendo "recurso de amparo" a fin de obtener la desocupación del inmueble: invocó la sentencia de esta Corte, de fecha 27 de diciembre de 1957, recaída en el "caso Siri", "las garantías a la libertad de trabajo (art. 14); a la propiedad (artículo 17); a la libre actividad (art. 19); de la Constitución Nacional", que estarían afectadas e hizo presente que la situación que planteaba era de "una gravedad extraordinaria. Al acto delictuoso de la ocupación de una fábrica y la desposesión de sus legítimos propietarios, se suman los constantes pedidos de amparo que por mi parte vengo repitiendo ante las autoridades policiales y administrativas y que formalizo con este escrito". El mismo día, la Cám. de Apelación antes mencionada desechó el recurso planteado con el fundamento de "que el recurso de "habeas corpus", como ha resuelto invariablemente este tribunal y lo tiene decidido la más autorizada doctrina, tiene por objeto esencial la protección de la libertad personal o corporal y no puede hacerse extensivo a la protección de otros derechos que se pretenden vulnerados. Tales derechos deben ejercitarse conforme a los respectivos procedimientos creados por las leyes de la materia" (Corte Federal, Fallos: 216:606; JA, 1950-III-486, entre otros).

Contra esta sentencia, el interesado interpuso recurso extraordinario, el cual, concedido por la Cám. de Apelación, llega ahora a la decisión de esta Corte.

Considerando: Que, ante todo, corresponde apartar el fundamento expresado por el tribunal a quo para desechar la pretensión

del interesado. Este no dedujo recurso de "habeas corpus", sino de amparo, invocando los derechos constitucionales de la libertad de trabajo, de la propiedad y de la libre actividad, o sea, dedujo una garantía distinta a la que protege la libertad corporal y que, a semejanza del habeas corpus, procura asimismo una protección expeditiva y rápida que emana directamente de la Constitución. Esta Corte lo ha declarado así en la sentencia de fecha 27 de diciembre del año próximo pasado en la causa "Siri Angel" (Fallos: 239:450 —LA LEY, 89-532, fallo núm. 41.675—), con fundamentos que se dan aquí por reproducidos en todo lo pertinente.

Que si bien en el precedente citado la restricción ilegítima provenía de la autoridad pública y no de actos de particulares, tal distinción no es esencial a los fines de la protección constitucional. Admitido que existe una garantía tácita o implícita que protege los diversos aspectos de la libertad individual (art. 33, Constitución Nacional), ninguna reserva cabe establecer de modo que excluya en absoluto y "a priori" toda restricción que emane de personas privadas.

Es verosímil presumir que, en el ánimo de los constituyentes de 1853, las garantías constitucionales tuvieron como inmediata finalidad la protección de los derechos esenciales del individuo contra los excesos de la autoridad pública. En el tiempo en que la Constitución fue dictada, frente al individuo solo e inerme no había otra amenaza verosímil e inminente que la del Estado. Pero los constituyentes tuvieron la sagacidad y la prudencia de no fijar exclusivamente en los textos sus temores concretos e históricos, sino, más bien, sus aspiraciones y sus designios permanentes y aun, eternos: la protección de la libertad. Esto último es lo que resulta del inequívoco y vehemente espíritu liberal de la ley suprema, aquello otro lo que se comprueba objetivamente en los textos constitucionales mismos. Nada hay, ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución, que permita afirmar que la protección de los llamados "derechos humanos" —porque son los derechos esenciales del hombre— esté circunscripta a los ataques que provengan sólo de la autoridad. Nada hay, tampoco, que autorice la afirmación de que el ataque ilegítimo, grave y manifiesto contra cualquiera de los derechos que integran la libertad. "Iato sensu", carezca de la protección constitucional adecuada —que es, desde luego, la del "habeas corpus" y la del recurso de amparo, no la de los juicios ordinarios o la de los interdictos, con traslados, vistas, ofrecimientos de

258

prueba, etc.—por la sola circunstancia de que ese ataque emane de otros particulares o de grupos organizados de individuos. Intentar construcciones excesivamente técnicas para justificar este distingo, importa interpretar la Constitución de modo que aparezca ella amparando realmente, no los derechos esenciales, sino las violaciones manifiestas de esos derechos. Las circunstancias concretas de esta causa constituyen por sí solas un ejemplo significativo.

Aun menos admisible es el distingo a que antes se ha hecho referencia, considerando las condiciones en que se desenvuelve la vida social de estos últimos 50 años. Además de los individuos humanos y del Estado, hay ahora una tercera categoría de sujetos, con o sin personalidad jurídica, que sólo raramente conocieron los siglos anteriores: los consorcios, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las grandes empresas, que acumulan casi siempre un enorme poderío material o económico. A menudo sus fuerzas se oponen a las del Estado y no es discutible que estos entes colectivos representan, junto con el progreso material de la sociedad, una nueva fuente de amenazas para el individuo y sus derechos esenciales.

Si, en presencia de estas condiciones de la sociedad contemporánea, los jueces tuvieran que declarar que no hay protección constitucional de los derechos humanos frente a tales organizaciones colectivas, nadie puede engañarse de que tal declaración comportaría la de la quiebra de los grandes objetivos de la Constitución y, con ella, la del orden jurídico fundamental del país. Evidentemente, eso no es así. La Constitución no desampara a los ciudadanos ante tales peligros ni les impone necesariamente recurrir a la defensa lenta y costosa de los procedimientos ordinarios. Las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción: "Las leyes disponen para lo futuro", dice el art. 3° del Cód. Civil, con un significado trascendente que no se agota, por cierto, en la consecuencia particular que el precepto extrae a continuación. Con mayor fundamento, la Constitución, que es la ley de las leyes y se halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria de poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempo de su sanción. Este avance de los principios consti-

tucionales, que es de natural desarrollo y no de contradicción, es la obra genuina de los intérpretes, en particular de los jueces, quienes deben consagrar la inteligencia que mejor asegure los grandes objetivos para que fué dictada la Constitución. Entre esos grandes objetivos y aun el primero entre todos, está el de "asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino" (Preámbulo).

Con respecto a la protección de la libertad corporal, la interpretación amplia es la que surge del pertinente precepto de la ley suprema: "Nadie puede ser... arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente", dice el art. 18 con fórmula muy general, lo que significa establecer que, no tratándose de esa única hipótesis estricta, toda privación ilegítima de la libertad personal, sin distinción alguna acerca de quien emana, autoriza el amparo de la Constitución. Esta amplitud del "hábeas corpus" es la que corresponde a la tradición del recurso en el derecho angloamericano—fuente inmediata del nuestro, a través de la Carta de los Estados Unidos del Norte—y si bien ha sido indebidamente restringido por la mayoría de los códigos procesales—que han tomado por "radio" lo que era sólo "ocasio"—, es la que corresponde a la letra y al espíritu de la Constitución. Así lo reconocen diversos tratadistas de nuestro derecho: "La ley no debe dar una garantía limitada, una protección parcial, diremos así, contra los actos de determinados poderes. Contra todos los poderes, incluso el judicial, contra los avances de los particulares, en cuanto afectan las garantías individuales, debe ella tener el mismo imperio e igual eficacia" (Tomás Jofré, "Manual de procedimiento criminal", Buenos Aires, 1914, núm. 164). Esta crítica del eminente jurista, exacta con respecto a la ley de procedimiento, no alcanza al texto amplio de la ley suprema. Entre las Constituciones de provincias, es digna de señalar la de Entre Ríos, que conserva expresamente el alcance tradicional del "hábeas corpus", extendiéndolo, aun a la protección de cualquiera de las garantías establecidas en la Constitución Nacional o provincial o las leyes (art. 25).

La misma amplitud corresponde reconocer al recurso de amparo, que esta Corte, en el precedente antes mencionado (Fallos: 239:459), extrajo de la sabia norma del art. 33 de la Constitución. Sin una reseña que, expresa o implícitamente, emane de los preceptos constitucionales y que imponga una inteligencia restringida del recurso de amparo,

la interpretación amplia es la que mejor consulta los grandes objetivos de la ley suprema y las genuinas finalidades de aquellas garantías. Lo que primordialmente tienen en vista el hábeas corpus y el recurso de amparo, no es el origen de la restricción ilegítima a cualquiera de los derechos fundamentales de la persona humana, sino estos derechos en sí mismos, a fin de que sean salvaguardados. Dichas garantías no atienden unilateralmente a los agresores, para señalar distinciones entre ellos, sino a los agredidos, para restablecer sus derechos esenciales. La Constitución está dirigida irrevocablemente a asegurar a todos los habitantes "los beneficios de la libertad" y este propósito, que se halla en la raíz de nuestra vida como nación, se debilita o se corrompe cuando se introducen distinciones que, directa o indirectamente, se traducen en obstáculos o postergaciones para la efectiva plenitud de los derechos.

En el mismo sentido, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 10 de diciembre de 1948, establece en su art. 8°: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley".

Siempre que aparezca, en consecuencia, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo. Todo lo que puede añadirse es que, en tales hipótesis, los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia—lo mismo que en muchas otras cuestiones propias de su alto ministerio—a fin de no decidir, por el sumáximo procedimiento de esta garantía constitucional, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponde resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios. Pero, guardadas la ponderación y la prudencia debidas, ningún obstáculo de hecho o de derecho debe impedir o retardar el amparo constitucional. De otro modo, habría que concluir que los derechos esenciales de la persona humana carecen en el derecho argentino de las garantías indispensables para su existencia y plenitud, y es obvio que esta conclusión no puede ser admitida sin

serio menoscabo de la dignidad del orden jurídico de la Nación.

En el caso de autos, se trata de la ocupación material de una fábrica por parte del personal obrero, determinada exclusivamente por un conflicto de carácter laboral con la empresa. Los ocupantes no han invocado ni pretenden tener ningún derecho a la posesión o detención de la fábrica. Según sus manifestaciones expresas y concordantes, la ocupación obedece al conflicto existente con la empresa patronal y se mantienen en el inmueble "sin ejercer violencia alguna, y defendiendo de esa manera su trabajo y a la espera de una resolución definitiva".

Ahora bien, la acción directa, o sea "el aseguramiento o la satisfacción de una pretensión por autoridad propia" (Enneccerus-Nipperday, "Derecho civil. Parte general", vol. II, § 223, Barcelona, 1935), no está consagrada por nuestra legislación, salvo en los casos de legítima defensa o de estado de necesidad, que presuponen indispensablemente la circunstancia de que el agente no pueda obtener en tiempo el auxilio de la autoridad. Con respecto a la posesión de las cosas, es un caso particular de aquellas defensas el legislado por el art. 2470 del Cód. Civil. Pero ni este código ni otra ley alguna de nuestro ordenamiento reconocen a nadie, sin mediar aquellas situaciones de excepción, la facultad de recurrir por sí mismo a las vías de hecho para asegurar o defender lo que estima su derecho y mantenerse en ellas ante la pasiva presencia de la autoridad pública. Ningún precepto legal confiere esa facultad a los obreros o a cualquier otro sector del pueblo argentino.

No se trata de negar o discutir la existencia del derecho de huelga ni poner en duda la legitimidad de las reclamaciones de los obreros en el conflicto que mantienen con la empresa patronal, aspectos absolutamente extraños a la instancia extraordinaria de esta Corte en la ocasión presente. Lo que aquí se afirma es la obvia conclusión de que todos los ciudadanos están sometidos a las leyes y que ninguno puede invocar en su favor derechos supra legales, es decir, derechos que existirían por encima y con prescindencia de las normas que integran el derecho positivo argentino. No otra cosa significa decir, desde el punto de vista del imperio de la ley, que una comunidad humana exista como Estado de Derecho.

De las circunstancias de esta causa y, en particular, de las declaraciones expresas de los obreros que ocupan la fábrica, surge de

modo manifiesto e indudable la ilegitimidad de esa ocupación. Nada hay, por tanto, en este solo aspecto de la ocupación, que corresponda diferir a los procedimientos ordinarios establecidos por las leyes para la dilucidación de los aspectos de fondo del conflicto gremial y de los derechos de las partes. Nada hay tampoco que requiera ser debatido en una acción real o en un interdicto posesorio. Aun en la hipótesis de que los obreros tuvieran toda la razón y la empresa ninguna, sería siempre verdad que la ocupación de la fábrica por aquéllos es ilegítima, como vía de hechos no autorizada por nuestras leyes.

También es manifiesto el agravio serio e irreparable que resulta de esta situación para los propietarios de fábricas y aun para los intereses generales. La ocupación de los obreros dura desde hace casi 3 meses y desde entonces la fábrica está "totalmente paralizada", sin que pueda saberse qué tiempo tardará aún para que el conflicto sea resuelto por las autoridades competentes ni cuál es el estado de los procedimientos respectivos. La magnitud del agravio y su carácter irreparable son, así, patentes.

Que, como surge de las consideraciones que anteceden, se hallan reunidas en este caso las condiciones necesarias para la procedencia del recurso de amparo deducido. Los hechos de la causa revelan de modo indudable que existe una restricción ilegítima de los derechos constitucionales invocados por el recurrente: desde luego, el de propiedad; también y, sobre todo, el de la libertad de trabajo, pues lo ocupado por los obreros no es un inmueble baldío o improductivo, sino una fábrica en funcionamiento y mediante la cual el propietario ejerce su actividad económica de fabricante.

En estas condiciones, no es juicioso pretender que el afectado reclame la devolución de su propiedad por los procedimientos ordina-

rios; si cada vez que, a raíz de un conflicto, muchas personas ocupan materialmente una fábrica, un instituto privado de enseñanza o cualquier otro establecimiento, los propietarios no tuvieran más recurso, para defender sus derechos constitucionales, que deducir un interdicto posesorio o de despojo, con múltiples citaciones a estar a derecho para todos y cada uno de los ocupantes, con la facultad de éstos de designar sus propios abogados, de contestar traslados y vistas, de ofrecer y producir pruebas, etc., cualquiera comprende a qué quedaría reducida la protección de los derechos que habrían concedido las leyes y de qué modo habría quedado subvertido el orden jurídico del país. En situaciones como las mencionadas, que es también la de estos autos, la protección judicial de los derechos constitucionales no tolera ni consiente semejantes dilaciones.

Por ello, habiendo dictaminado el procurador general, se revoca la sentencia apelada de fs. 5, haciendo uso de la facultad que acuerda a esta Corte el art. 16, 2ª parte de la ley 48, y habida cuenta de las circunstancias existentes en el expediente K. 21. XIII, de las que resulta haberse oído a los ocupantes del inmueble de que trata la causa, se hace lugar al recurso de amparo deducido. En consecuencia, y sin más trámite, líbrese oficio por secretaría al comisario de Villa Lynch. Prov. de Buenos Aires, a fin de que proceda de inmediato, con habilitación de días y horas, a entregar a Sabatino Kot, representante de Samuel Kot (Soc. de Resp. Ltda.), el establecimiento textil situado en la calle Arias 228, Villa Lynch, partido de San Martín, libre de todo ocupante. — *Alfredo Orgaz. — Benjamín Villegas Basavilbaso. — Juan C. Beccar Varela. — En disidencia: Aristóbulo Aráoz de Lamadrid. — Julio Oyhanarte.*

Disidencia:

Omissis...

4. MILL DE PEREYRA

CONSTITUCION NACIONAL

Constitucionalidad — Defensa en juicio — Facultades de los jueces — Intangibilidad de la remuneración de los jueces — "Iura novit curia" — Juez — Ley de Convertibilidad — Principio de división de poderes — Remuneración.

Hechos

Jueces de Corrientes demandaron a dicha provincia por actualización de haberes frente

al deterioro provocado por la inflación, invocando la intangibilidad constitucional de los

misos. El Superior Tribunal local declaró inconstitucional de oficio la ley 23.928, en cuanto prohíbe todo mecanismo de indexación con posterioridad al 1º de abril de 1991, e hizo lugar a la demanda. Concedido parcialmente el recurso extraordinario, la Corte Suprema consideró que los jueces podían ejercer de oficio el control de constitucionalidad. Sin embargo, revocó la declaración emitida por el inferior entendiendo que la norma no violaba garantía alguna.

1. Los jueces están facultados para ejercer de oficio el control de constitucionalidad —en el caso, se declaró inconstitucional la ley de convertibilidad 23.928 (Adla, LI-B, 1752) en un juicio por actualización de haberes judiciales, decisión que fue revocada por la Corte al entender que dicha norma no viola garantía alguna—, sin que ello atente contra el principio de división de poderes, pues siendo legítimo el control de constitucionalidad en sí mismo, carece de sentido sostener que no se produce un avance indebido del Poder Judicial cuando media petición de parte y sí cuando no la hay.

2. La declaración de inconstitucionalidad de oficio —en el caso, de la ley de convertibilidad 23.928 (Adla, LI-B, 1752) en un juicio por actualización de haberes judiciales, decisión que fue revocada por la Corte al entender que dicha norma no viola garantía alguna— procede sólo si la incompatibilidad entre la norma invalidada y el texto constitucional resulta manifiesta e indubitable, pues tal medida reviste suma gravedad institucional, debiendo recurrirse a ella sólo cuando la estricta necesidad lo requiere.

3. La declaración de inconstitucionalidad de oficio —en el caso, de la ley de convertibilidad 23.928 (Adla, LI-B, 1752) en un juicio por actualización de haberes judiciales, decisión que fue revocada por la Corte al entender que dicha norma no viola garantía alguna— respeta la presunción de legitimidad de los actos estatales, pues tal presunción cede cuando los actos cuestionados contrarían una norma de jerarquía superior.

4. La declaración de inconstitucionalidad de oficio —en el caso, de la ley de convertibilidad 23.928 (Adla, LI-B, 1752) en un juicio por actualización de haberes judiciales, decisión que fue revocada por la Corte al entender que dicha norma

respeto las garantías constitucionales— no lesiona el derecho de defensa en juicio, pues lo contrario conduciría a descalificar toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por las partes so pretexto de no haber podido expedirse sobre su aplicación al caso concreto.

5. La ley de convertibilidad 23.928 (Adla, LI-B, 1752), en cuanto prohíbe todo mecanismo de indexación con posterioridad al 1º de abril de 1991, no deviene inconstitucional en su aplicación a los sueldos de los jueces —en el caso, la Corte revocó la inconstitucionalidad declarada de oficio por el inferior un juicio para actualizar haberes judiciales—, aún frente al deterioro producido por la inflación, pues la intangibilidad de tales sueldos —art. 110, Constitución Nacional— debe conciliarse con la facultad que tiene el Congreso para hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras —art. 75 inc. 11—.

6. La ley de convertibilidad 23.928 (Adla, LI-B, 1752), en cuanto prohíbe todo mecanismo de indexación con posterioridad al 1º de abril de 1991, no vulnera sino que procura resguardar la intangibilidad de las retribuciones judiciales prevista en el art. 110 de la Constitución Nacional —en el caso, la Corte revocó la inconstitucionalidad declarada de oficio por el inferior en un juicio para actualizar tales haberes—, ya que las preserva del proceso inflacionario mediante el establecimiento de un equilibrio monetario que se quebraría si se conservaran los criterios indexatorios (del voto del doctor Vázquez).

7. La declaración de inconstitucionalidad de oficio —en el caso, la de la ley de convertibilidad 23.928 en un juicio por actualización de haberes judiciales, decisión que fue revocada por la Corte al entender que dicha norma respeta las garantías constitucionales— no importa un avasallamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues dicha tarea hace a la esencia del Poder Judicial, una de cuyas funciones específicas consiste en controlar la constitucionalidad de la actividad estatal, a fin de mantener la supremacía de la Constitución Nacional —art. 31— (del voto del doctor Boggiano).

8. Los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de los actos estatales.

les —en el caso, la ley de convertibilidad 23.928 (Adla, LI-B, 1752) en un juicio por actualización de haberes judiciales, decisión que fue revocada por la Corte al entender que dicha norma no viola garantías constitucionales—, pues tal declaración es una cuestión de derecho insita en el adagio "iura novit curia", que incluye el deber de mantener la supremacía constitucional—art.31— (del voto del doctor Boggiano).

9. La declaración de inconstitucionalidad de oficio —en el caso, de la ley de convertibilidad 23.928 (Adla, LI-C, 1752) en un juicio por actualización de haberes judiciales, decisión que fue revocada por la Corte al entender que dicha norma respeta las garantías constitucionales— no lesiona el derecho de defensa en juicio, si los litigantes tuvieron oportunidad de ser oídos sobre el punto en el remedio federal y su contestación (del voto de los doctores López y Bossert).

10. La ley de convertibilidad 23.928 (Adla, LI-C, 1752) constituye una decisión clara y terminante del Congreso de la Nación de ejercer las facultades para hacer sellar la moneda y fijar su valor según el art. 75 inc. 11 de la Constitución Nacional —en el caso, la Corte revocó la inconstitucionalidad declarada de oficio por el inferior en el marco de una acción para actualizar haberes judiciales—, habiendo sido derogadas no sólo las disposiciones legales que permitían actualizar créditos, sino también las de orden pretoriano (del voto de los doctores López y Bossert).

11. Los jueces carecen de facultades para declarar de oficio la inconstitucionalidad de los actos estatales (del voto en disidencia parcial de los doctores Nazareno y Petracchi).

12. La declaración de inconstitucionalidad de oficio atenta contra el principio de división de poderes, a menos que el acto estatal en cuestión afecte la autonomía funcional del Poder Judicial, sea por exceder las atribuciones jurisdiccionales de los tribunales o que la Corte Suprema ejerza las facultades para dictar su reglamento interior según el art. 113 de la Constitución Nacional (del voto en disidencia parcial del doctor Moliné O'Connor).

13. El control de inconstitucionalidad de oficio lesiona la garantía de defensa en juicio

—art. 18, Constitución Nacional—, ya que al no mediar oportunidad procesal para debatir en forma amplia y explícita sobre la constitucionalidad del acto estatal en cuestión se viola la igualdad de las partes en el proceso (del voto en disidencia parcial del doctor Moliné O'Connor).

14. La declaración de inconstitucionalidad de oficio no importa ejercicio ordinario de la facultad que tiene el juez para seleccionar el derecho aplicable al caso con prescindencia de su invocación por las partes —"iura novit curia"—, pues en este supuesto el magistrado aplica la legislación vigente mientras que cuando ejerce el control de constitucionalidad sin que medie planteo de parte abroga por su voluntad una norma regularmente sancionada que se encuentra en vigor y goza de presunción de validez (del voto en disidencia parcial del doctor Moliné O'Connor).

CS, 2001/09/27.— Mill de Pereyra, Rita A. y otros c. Provincia de Corrientes (*).

Omissis...

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2001.

Considerando: 1. Que contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes que hizo lugar a la demanda promovida por jueces que reclamaron el cumplimiento de la garantía de la intangibilidad de sus remuneraciones, la vencida interpuso el recurso extraordinario que fue parcialmente concedido. Con relación a los aspectos denegados, dedujo el pertinente recurso de queja que corre agregado a la presente.

2. Que para así decidir sostuvo que "en virtud del paulatino deterioro operado en el valor adquisitivo de los importes nominales de los haberes", que deriva "del proceso inflacionario que afectara nuestro signo monetario" y que genera "la disminución de sus valores reales", se vio frustrada "la garantía de la intangibilidad a su respecto". Asimismo, rechazó la defensa de prescripción que

(*) Publicado en: DJ 2001-3, 807 - LA LEY 2001-F, 891 - ED 28/12/2001, 6 - ED 195 - JA 27/02/2002, 51 - JA 2002-I - LA LEY 2002-A, 34 - LA LEY 2003-A, 234, con nota de Claudio D. Gómez - CS Fallos 324:3219 - Colección de Análisis Jurisprudencial Elms. de Derecho Administrativo - Julio Rodolfo Comadira, 613 - Colección de Análisis Jurisprudencial Teoría del Estado - Director: Mario Héctor Resnik - Editorial LA LEY, 2004, 385.

articuló la demandada con fundamento en el art. 4032 del Cód. Civil y, por último, sin que mediara pedido de parte, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 7, 10 y 13 de la ley 23.928, de convertibilidad del austral, y de la ley 4558, de consolidación de la deuda pública provincial.

3. Que el recurrente sostiene, en síntesis, que: a) no surge de autos que el Estado provincial haya incurrido en incumplimiento de la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones que ampara a los actores sino que, por el contrario, el gobierno de la provincia efectuó importantes recomposiciones salariales a los magistrados, mejoras que fueron muy superiores a las de otros sectores del empleo público; b) no resulta aplicable al caso el plazo de prescripción establecido por el art. 4027 del Cód. Civil sino el del art. 4032; c) la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 4558 —decretada de oficio— viola el principio de congruencia y el de la defensa en juicio; y d) estas leyes no son violatorias de ninguno de los derechos consagrados en la Constitución Nacional o provincial y, dictadas con fundamento en el ejercicio del poder de policía de emergencia del Estado, procuran asegurar la supremacía del interés general y eliminar la inflación que produce la corrección por índices del valor monetario.

4. Que deben desestimarse los agravios del apelante en cuanto atribuyen arbitrariedad a lo decidido en cuanto consideró que los reajustes practicados en las remuneraciones percibidas entre enero de 1984 y abril de 1988 fueron insuficientes para mantener la garantía de intangibilidad de la remuneración de los jueces demandantes y aplicable el plazo de cinco años de prescripción, pues remiten al análisis de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas, como regla y por su naturaleza, a la instancia extraordinaria del art. 14 de la ley 48 máxime cuando, como sucede en el caso, la sentencia cuenta con fundamentos suficientes que la colocan al abrigo de la tacha de arbitrariedad.

5. Que igual suerte corre la queja dirigida a cuestionar la invalidación de la ley provincial 4558 porque, según ha resuelto el tribunal, la declaración de inconstitucionalidad de leyes locales no constituye cuestión federal que sustente el recurso extraordinario, ya que no existe resolución favorable a la validez de la norma local cuestionada (Fallos: 295:797; 311:955 y sus citas).

6. Que, en cambio, es formalmente procedente el recurso extraordinario pues se cuestiona la constitucionalidad de la ley 23.928 y

la decisión del superior tribunal de la causa es contraria a las peticiones del recurrente (art. 14 inc. 1°, ley 48).

7. Que el a quo, como se dijo, juzgó que la Provincia de Corrientes incurrió en incumplimiento de la garantía de incolumidad de las remuneraciones de los magistrados. Sobre la base del art. 143 de la constitución local —reproducción, casi exacta, del entonces art. 96 de la Constitución Nacional— reputó aplicable al sub iudice tanto éste como la doctrina elaborada por esta Corte en torno a él. Consideró, también, que la ley 23.928, en cuanto no admite la actualización monetaria a partir del 1° de abril de 1991, resulta inconstitucional por quebrantar aquella garantía.

8. Que, en lo que aquí interesa, aquella dispone que "en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1° del mes de abril de 1991" (art. 7°); deroga "todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios" (art. 10) y declara que "la presente ley es de orden público" y que "ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos" (art. 13).

9. Que, en primer lugar y en cuanto al agravio referente a la declaración de oficio de la inconstitucionalidad, corresponde remitirse al voto de los jueces Fayt y Belluscio en el caso de Fallos: 306:303 —La Ley, 1984-B, 431—, donde se expresó que "no puede verse en la admisión de esa facultad la creación de un desequilibrio de poderes en favor del Judicial y en mengua de los otros dos, ya que si la atribución en sí no es negada, carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay. Tampoco se opone a la declaración de inconstitucionalidad de oficio la presunción de validez de los actos administrativos, o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando contrarían una norma de jerarquía superior, lo que ocurre en las leyes que se oponen a la Constitución. Ni, por último, puede verse en ella menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese debería también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal, no invocada por ellas so pretexto de no haber

podido los interesados expedirse sobre su aplicación en el caso" (considerando 5°).

10. Que, sin embargo, el ejercicio de tal facultad en orden a la misión de mantener el imperio de la Constitución sólo puede considerarse autorizado en situaciones muy precisas.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que su existencia no importa desconocer que la invalidez constitucional de una norma sólo puede ser declarada cuando la violación de aquélla sea de tal entidad que justifique la abrogación, en desmedro de la seguridad jurídica (Fallos: 306:303 citado, voto de los jueces Fayt y Belluscio, considerando 19). La declaración de inconstitucionalidad es —según conocida doctrina de este tribunal— una de las más delicadas funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad, al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 247:121 y sus citas). Es por ello que con más rigor en este caso, la declaración de inconstitucionalidad sólo será procedente cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa (Fallos: 260:153, considerando 3° y sus citas).

En segundo término, debe ponderarse que su ejercicio no supone en modo alguno la admisión de declaraciones en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual debe optarse entre la aplicación de una norma de rango inferior en pugna con la Constitución Nacional o de ésta, a efectos de resolver un conflicto contencioso en los términos del art. 2° de la ley 27 (doctrina de Fallos: 306:303, voto de los jueces Fayt y Belluscio, considerando 4°).

De estos recaudos habrá de derivar necesariamente el carácter incidental de este tipo de declaración de inconstitucionalidad, en el sentido de que, por definición y al tratarse de una declaración oficiosa, no habrá sido solicitada por las partes; de allí que sólo será necesaria para remover un obstáculo —la norma inconstitucional— que se interponga entre la decisión de la causa y la aplicación directa a ésta de la Ley Fundamental; dicho en otros términos, esa declaración será el presupuesto para el progreso de otra pretensión (causa A.529.XXII. "Asociación Bancaria c. Provincia del Chubut", sentencia del 15 de junio de 1989) o, en su caso, defensa.

Y, finalmente, deberá tenerse presente que de acuerdo a la doctrina de este Tribunal, las decisiones que declaran la inconstitucionalidad de la ley, sólo producen efectos dentro de la causa y con vinculación a las relaciones jurídicas que la motivaron y no tienen efecto derogatorio genérico (Fallos: 247:700; 248:702; 255:262; 264:364; 315: 276; 322:528 entre muchísimos otros).

11. Que, con relación al fondo del asunto, esta Corte ha interpretado reiteradamente que la intangibilidad de las retribuciones de los jueces es garantía de la independencia del Poder Judicial, de manera que cabe considerarla, juntamente con la inamovilidad, como garantía de funcionamiento de un poder del Estado. Asimismo, ha sostenido que la garantía de irreductibilidad de los sueldos está conferida no para exclusivo beneficio personal o patrimonial de los magistrados sino para resguardar su función de equilibrio tripartito de los poderes del Estado, de modo que la vía abierta en esta causa no tiende tanto a defender un derecho de propiedad de los actores como particulares, y a título privado, sino la ya referida garantía de funcionamiento independiente del Poder Judicial, cuya perturbación la Ley Suprema ha querido evitar al consagrar rotundamente la incolumidad de las remuneraciones judiciales (Fallos: 315:2386).

12. Que igualmente, en Fallos: 176:73, el Tribunal dijo que la intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira de la institución del Poder Judicial, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión de parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia. Sustancialmente, en consecuencia, la intangibilidad de los sueldos no es estrictamente una garantía en favor de tales magistrados, sino un seguro de su independencia efectiva que beneficia a la misma sociedad en tanto tiende a preservar la estricta vigencia del estado de derecho y el sistema republicano de gobierno.

13. Que, por otra parte, debe tenerse presente que la interpretación de la Constitución debe realizarse de modo que resulte un conjunto armónico de disposiciones con una unidad coherente. Para tal fin, cada una de sus normas debe considerarse de acuerdo al contenido de las demás; la inteligencia de sus cláusulas debe cuidar de no alterar el equilibrio del conjunto (Fallos: 296:432). En la búsqueda de esa armonía y equilibrio debe evitarse que las normas constitucionales sean puestas en pugna entre sí, para lo cual se

debe procurar dar a cada una el sentido que mejor las concierte y deje a todas con valor y efecto. Con estas pautas, no es válido asignar —como lo hizo la corte local— a la garantía que consagra la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, una extensión tal que desconozca las facultades que el art. 75 inc. 11 de la Ley Fundamental confiere al Congreso de la Nación para "hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras".

14. Que, en este orden de ideas, la ley 23.928 constituye una decisión clara y terminante del Congreso de la Nación de ejercer las funciones que le encomienda el art. 75 inc. 11, ya referido. Ante tal acto legislativo no sólo han quedado derogadas disposiciones legales sino que además deben ser revisadas las soluciones de origen pretoriano que admitían el ajuste por depreciación, en cuanto, precisamente, se fundaron en la falta de decisiones legislativas destinadas a enfrentar el fenómeno de la inflación. De ahí que —como esta Corte dijo en Fallos: 315:158— no puede

mantenerse idéntico temperamento respecto de este punto con relación a períodos posteriores al 1° de abril de 1991.

Por ello y oído el procurador general, se rechaza la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y, con el alcance indicado, se revoca la sentencia. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte una nueva con arreglo a la presente. Costas por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68, segunda parte, Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación). Intégrese el depósito. Archívese la queja. Notifíquese y remítase. — Julio S. Nazareno (en disidencia parcial). — Eduardo Moliné O'Connor (en disidencia parcial). — Carlos S. Fayt. — Augusto C. Belluscio. — Enrique S. Petracchi (en disidencia parcial). — Antonio Boggiano (según su voto). — Guillermo A. F. López (según su voto). — Gustavo A. Bossert (según su voto). — Adolfo R. Vázquez (según su voto).

Omissis...

5. BANCO COMERCIAL DE FINANZAS

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Corte Suprema de Justicia de la Nación — Crédito privilegiado — Derechos del acreedor — Entidad financiera — Facultades de los jueces — Gastos del concurso — Iura novit curia — Juez — Jurisprudencia — Liquidación de entidad financiera — Obligaciones del juez — Privilegios — Quiebra — Recurso extraordinario — Supremacía constitucional.

Hechos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo lugar a una queja por denegación de recurso extraordinario y declarando procedente este último remedio, dejó sin efecto la resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que, al admitir un recurso local de inaplicabilidad de ley, había establecido que un crédito del Banco Central de la República Argentina por la liquidación de una entidad financiera gozaba de la preferencia del art. 264 de la ley concursal 24.522.

1. Cabe dejar sin efecto la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que, al admitir un recurso de inaplicabilidad de ley, dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del decreto 2075/93 (Adla, LIII-D, 4326), en

cuanto dispone que deben entenderse como gastos del concurso, con la preferencia del art. 264 de la ley 24.522 (Adla, LV-D, 4381), los de cualquier naturaleza efectuados por el Banco Central de la República Argentina luego de la liquidación de una entidad financiera, sin considerar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se había pronunciado por la inconstitucionalidad de dicha norma.

2. Si bien los tribunales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de leyes en abstracto, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa de parte interesada —en el caso, se declaró inconstitucional de oficio el decreto 2075/93 (Adla, LIII-D, 4326), en cuanto dispone que deben entenderse como gastos del concurso, con la preferencia del art. 264 de

la ley 24.522 (Adla, LV-D, 4381), los de cualquier naturaleza efectuados por el Banco Central de la República Argentina luego de la liquidación de una entidad financiera—, pues se trata de una cuestión de derecho, hallándose comprendida en la potestad de suplir el derecho no invocado o invocado erróneamente el deber de mantener la supremacía constitucional.

3. Debe revocarse por arbitraria a los fines del recurso extraordinario —art. 14, ley 48 (Adla, 1852-1880, 364)— la resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que, al acoger un recurso de inaplicabilidad de ley, estableció que un crédito del Banco Central de la República Argentina por la liquidación de una entidad financiera gozaba de la preferencia del art. 264 de concursal 24.522 (Adla, LV-D, 4381), si ello importó reconocer sin fundamento alguno la existencia de una acreencia que se hallaba controvertida (del voto del doctor Petracchi).

CS, 2004/08/19.— Banco Comercial de Finanzas (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/quiebra (*).

Omissis...

Buenos Aires, agosto 19 de 2004.

Considerando: 1. Que los antecedentes del caso y, en especial, los planteos que son traídos a conocimiento de este Tribunal han sido claramente expuestos en los apartados I y II del dictamen del señor Procurador General, a cuyas consideraciones corresponde remitir en razón de brevedad.

2. Que reiteradamente ha señalado esta Corte que "es elemental, en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella" (Fallos: 311:2478, entre muchos otros).

(*) Publicado en LA LEY 22/11/2005, 5, con nota de Bárbara Figueira; Christian J. Musitani - LA LEY 2005-F, 453, con nota de Bárbara Figueira; Christian J. Musitani - LA LEY 30/08/2004, 5-DJ/2004-3, 115 - IMP 2004-B, 2896 - LA LEY 2005-B, 842, con nota de Fernando N. Bonina - Colección de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Administrativo - Julio Rodolfo Comadira, 622 - JA 2005-III, 441

3. Que, asimismo, cabe recordar que si bien es exacto que los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuarse la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa de la parte interesada, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente —trasuntado en el antiguo adagio "iura novit curia"— incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 de la Carta Magna) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, desechando la de rango inferior (Fallos: 306:303, considerando 4° del voto de los jueces Fayt y Belluscio).

4. Que, además, se consignó que no podía verse en ello la creación de un desequilibrio de poderes en favor del judicial y en mengua de los otros dos, ya que si la atribución en sí no es negada, carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay. Tampoco se opone a la declaración de inconstitucionalidad de oficio la presunción de validez de los actos administrativos o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando se contraría una norma de jerarquía superior, lo que ocurre cuando las leyes se oponen a la Constitución. Ni, por último, puede verse en ella menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese debería, también, descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso (confr. fallo precedentemente citado, considerando 5°, Fallos: 324:3219 voto del juez Boggiano, considerandos 11, 13 y 14 y del juez Vázquez, considerandos 15, 16 y 17 y 19).

5. Que, sin embargo, el tribunal a quo —tras subrayar que ninguna de las partes había impugnado en el sub lite la constitucionalidad del decreto 2075/93— casó la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca —en cuanto había declarado la inconstitucionalidad de dicha norma de oficio— e hizo reposar sobre dichas circunstancias y en lo establecido por el art. 8° de la ley 24.144 la validez y aptitud reglamentaria que le reconoció, con olvido de que la constitucionalidad del refe-

rido decreto había sido ya desestimada por esta Corte en Fallos: 320:1386.

En consecuencia, cabe dejar sin efecto en este punto el fallo apelado y mantener la declaración de inconstitucionalidad del decreto 2075/93, decretada por la citada Cámara, en tanto encuadra como gasto del concurso a los gastos y adelantos de cualquier naturaleza efectuados por el Banco Central, con posterioridad a la liquidación del intermedio financiero, sin distinguir su naturaleza, causa u origen.

6. Que, independientemente de lo anterior, la decisión del tribunal a quo según la cual "...el crédito del Banco Central goza de la preferencia del art. 264 de la Ley de Concursos..." importó reconocer, sin dar fundamento, la existencia misma de la acreencia de la entidad, pese a que ella estaba enfáticamente controvertida, con el alcance que dicho banco pretendió, a fs. 74/76. La omisión en el tratamiento de esta última alegación —que, por cierto, había sido compartida por la cámara de apelaciones a fs. 123— torna también descalificable el fallo provincial desde la perspectiva que brinda la conocida doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias.

Por ello, oído el señor procurador general, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese, agréguese la queja al principal y, oportunamente, devuélvase. — Enrique S. Petracchi (según su voto). — Augusto C. Belluscio. — Carlos S. Fayt. — Antonio Boggiano. — Adolfo R. Vázquez. — E. Raúl Zaffaroni. — Elena I. Highton de Nolasco.

Voto del doctor Petracchi:

Considerando: 1. Que los antecedentes del caso y, en especial, los planteos que son traídos a conocimiento de este Tribunal han sido claramente expuestos en los apartados I y II del dictamen del señor Procurador General, a cuyas consideraciones corresponde remitir en razón de brevedad.

2. Que esta Corte reiteradamente ha establecido que en supuestos en los que —como en el caso— se plantea en el recurso extraordinario una cuestión relativa a la inteligencia o a la validez constitucional de normas federales y se formulan agravios con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, corresponde considerar en primer término la arbitrarie-

dad, puesto que de existir, en rigor, no habría sentencia propiamente dicha (Fallos: 323:1669, 2245, 2492; 324:2801, 3394; 325:279, 350, 878, 1218; 325:1633, entre muchos otros).

3. Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires —tras considerar que en esta causa ninguna de las partes había impugnado la constitucionalidad del decreto 2075/93— resolvió casar la sentencia de la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en cuanto había declarado de oficio la inconstitucionalidad de aquella norma. En consecuencia, dispuso que establecida la validez del decreto 2075/93 y su "...aptitud reglamentaria..." correspondía establecer concretamente si aquel decreto era aplicable a la acreencia que con carácter de crédito del concurso reclamó el Banco Central, esto es, la que se habría originado en el canje que dicho banco alegó haber efectuado, con posterioridad a la liquidación de la entidad fallida, otorgando Bonex a una serie de inversores a cambio de sus imposiciones, por aplicación de lo dispuesto en el decreto 36/90 (fs. 189 vta. del expte. principal).

4. Que, sin embargo, al efectuar dicho examen sólo transcribió el art. 1° del decreto 2075/93 y, seguidamente, se limitó a expresar que: "Se desprende, pues, que la referida acreencia originada por el canje de imposiciones para BONEX con posterioridad a la liquidación queda comprendida en los alcances de la norma transcripta y el Banco Central en su calidad de acreedor del concurso goza de la preferencia establecida por el art. 264 de la ley respectiva y en ello también asiste razón al recurrente" (fs. 190 del expte. principal).

5. Que, contrariamente a lo afirmado en el penúltimo párrafo del dictamen del señor Procurador General, la sentencia no fijó una doctrina legal para "todos los créditos" del Banco Central posteriores a la liquidación, sino que, específicamente, dejó establecido que la acreencia del Banco Central a que se ha hecho referencia precedentemente, "...goza de la preferencia del art. 264 de la Ley de Concursos..." (ver a fs. 193 vta. del expte. principal, la parte dispositiva de la sentencia) pero, al así hacerlo, no ponderó ninguna de las constancias ni de las alegaciones de las partes que pusieron en duda la existencia misma del crédito. En efecto, mientras el Banco Central sostuvo en su presentación ante la corte provincial que, a diferencia de lo sostenido por la parte contraria, "... quedaba suficientemente acreditado la existencia del crédito..." con la "...certificación contable que

264

fuera adjuntada por esta sindicatura...", elaborada sobre la base de los libros contables de dicho banco (fs. 140 vta. del expte. principal), tanto la fallida como la cámara, habían controvertido enfáticamente que aquella certificación contable pudiera tener tal virtualidad (ver, en especial, fs. 79/80 y 123 del expte. principal).

6. Que, en consecuencia, si bien es cierto que la jurisdicción que el recurso de inaplicabilidad de ley confiere al máximo tribunal provincial tiene por finalidad, en principio, dirimir la correcta aplicación del derecho con relación a los hechos definitivamente juzgados por los jueces inferiores, sin que resulte pertinente reexaminar la plataforma fáctica o realizar una ponderación íntegra del proceso —a excepción de los supuestos de "arbitrariedad" o "absurdo" elaborados por aquel tribunal—, lo cierto es que la decisión de la corte provincial, al establecer, sin más ni más, que "...el crédito del Banco Central goza de la preferencia del art. 264 de la Ley de Concur-

sos", importó reconocer, sin dar fundamento alguno —ni efectuar ninguna salvedad al respecto— la existencia misma de la acreencia del Banco Central que se hallaba controvertida con el alcance que dicho banco pretendió a fs. 74/76. Lo expresado autoriza a descalificar el pronunciamiento conforme a conocida jurisprudencia del Tribunal en materia de arbitrariedad de sentencias (ver doctrina de Fallos: 316:2464 y 2718; 322:2755; 325:1530 y 1696, entre muchos otros), sin que sea necesario el tratamiento de los restantes agravios del apelante.

Por ello, oído el señor Procurador General, se declara admisible el recurso extraordinario, se hace lugar a la queja interpuesta y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese, agréguese la queja al principal y, oportunamente, devuélvase. — *Enrique S. Petracchi*.

6. ARANCIBIA CLAVEL

ACCION PENAL

Asociación ilícita — Constitución Nacional — Delito — Delitos de lesa humanidad — Derecho internacional público — Derecho penal internacional — Derechos humanos — Garantías constitucionales — Ley penal — Prescripción — Prescripción de la acción penal — Principio de legalidad — Procedimiento penal — Retroactividad de la ley — Terrorismo — Tratado internacional.

Hechos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado procedente una queja y el recurso extraordinario que había sido denegado por la Cámara Nacional de Casación Penal, dejó sin efecto la sentencia de este último tribunal, en cuanto había declarado extinta la acción penal por prescripción en la causa seguida por el delito de asociación ilícita con fines de persecución y exterminio de opositores políticos.

1. El delito de asociación ilícita perpetrado para perseguir opositores políticos por medio de homicidios, desapariciones forzadas de personas y tormentos reviste carácter de crimen contra la humanidad y, por ende, es imprescriptible, sin que corresponda declarar extinta la acción penal aun cuando haya transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2° en

función del art. 210 del Cód. Penal, pues tal disposición resulta desplazada por el derecho internacional consuetudinario y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (Adla, LXIII-E, 3843).

2. La aplicación retroactiva de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (Adla, LXIII-E, 3843) —en el caso, a una asociación ilícita tendiente a perseguir opositores políticos mediante homicidios, desapariciones forzadas y tormentos— no lesiona el principio "nulla poena sine lege", pues tales delitos usualmente son practicados por agencias estatales operando fuera del control del derecho penal, por lo que no es razonable la pretensión de le-

gitimar el poder genocida en virtud del paso del tiempo, máxime si se considera que aún antes de que comenzara a regir dicho tratado existía una costumbre internacional respecto de su imprescriptibilidad.

3. Cabe apartarse del principio según el cual la ley penal "ex post facto" no rige cuando empeora las condiciones de los acusados —en el caso, normas de rango constitucional sobre imprescriptibilidad de ciertos delitos—, si se está ante crímenes contra la humanidad —asociación ilícita tendiente a perseguir opositores políticos mediante homicidios, desapariciones forzadas y tormentos—, ya que se trata de supuestos que no han dejados de ser vivenciados por la sociedad entera, dada la magnitud y la significación que los atañe, por lo que no sólo permanecen vigentes para ésta, sino también para la comunidad internacional.

4. Configura crimen contra la humanidad —y por tanto imprescriptible— la asociación ilícita constituida para perseguir y exterminar opositores políticos mediante la comisión de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, homicidio y cualquier otro tipo de crimen contra la humanidad, pues están comprendidas en esta categoría de delitos las conductas que impliquen contribuir de algún modo en la comisión o tentativa de crímenes contra la humanidad por un grupo de personas que tengan una finalidad común arts. 7.1.h) y 25.3.d), Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 2° y 3.b), Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

5. En materia de crímenes contra la humanidad —en el caso, a una asociación ilícita tendiente a perseguir opositores políticos mediante homicidios, desapariciones forzadas y tormentos—, la aplicación de las disposiciones de derecho interno sobre prescripción de la acción penal constituye una violación del deber a cargo del Estado argentino de asegurar la vigencia de los derechos humanos en todas las estructuras del aparato gubernamental, lo que incluye prevenir, investigar y sancionar todas violaciones de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Adla, XLIV-B, 1250) (del voto del doctor Petracchi).

6. Se encuentra tipificado como delito del "ius gentium" —y por ende, imprescriptible—, el formar parte de una organización destinada a cometer delitos de lesa humanidad —en el caso, persecución y exterminio de opositores políticos mediante genocidio, homicidio, desaparición forzada y tormentos—, entre los cuales cabe incluir el terrorismo, según de definición que de dicha categoría de delitos efectúa el art. 6.c de la Carta del Tribunal Internacional de Nüremberg, al que remite la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (Adla, LXIII-E, 3843) (del voto del doctor Boggiano).

7. El principio de imprescriptibilidad —art. I, Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad— (Adla, LXIII-E, 3843) no puede verse supeditado ni, por ende, enervado por el principio de legalidad —art. 18, Constitución Nacional—, pues los tratados internacionales sobre Derechos Humanos deben interpretarse conforme al derecho internacional, en tanto éste es su ordenamiento jurídico, debiendo tenerse en cuenta que de nada serviría la referencia a los tratados hecha en la Constitución si su aplicación se viera frustrada o modificada por interpretaciones basadas en uno u otro derecho nacional (del voto del doctor Boggiano).

8. Entre el principio de no retroactividad que favorecería al autor de un delito contra el "ius gentium" y el principio de retroactividad aparente de los tratados internacionales sobre imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, debe prevalecer este último, que tutela normas imperativas del "ius cogens", siendo el conflicto entre ambos preceptos sólo aparente, pues las normas de "ius cogens" que castigan los citados delitos —en el caso, asociación ilícita conformada para perseguir y exterminar opositores políticos— han estado vigentes desde tiempo inmemorial (del voto del doctor Boggiano).

9. La agrupación para cometer delitos de lesa humanidad —en el caso, con fines de persecución y exterminio de opositores políticos— no sólo constituye crimen para la ley internacional —incorporado en el art. 118, Constitución Nacional—,

265

sino también para el derecho penal argentino, que prevé una clara descripción de la citada conducta y su respectiva sanción —art. 210, Cód. Penal—, preservándose debidamente el principio de legalidad, traducido en el adagio “nulla poena sine lege”, aun cuando tales normas no capten en toda su gravedad de los hechos reprobados por la comunidad internacional (del voto del doctor Maqueda).

10. Los estados nacionales tienen el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos —en el caso, mediante la declaración de su imprescriptibilidad y la prosecución del juicio criminal pese al vencimiento del plazo de prescripción del derecho interno—, procesar a los responsables y evitar su impunidad, entendida ésta como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos; debiendo combatirse tal situación por todos los medios legales disponibles (del voto del doctor Maqueda).

11. Es irrevisable por la vía del recurso extraordinario —art. 14, ley 48 (Adla, 1852-1880, 364)— la decisión que declara extinta la acción penal por prescripción si la parte acusadora no mantuvo en esta instancia el agravio relativo a la imprescriptibilidad de la acción con fundamento en la calidad de crimen de lesa humanidad del delito imputado, pues lo contrario vulneraría el derecho de defensa en juicio al no tener el imputado posibilidad de cuestionar dicha calificación (del voto en disidencia del doctor Belluscio).

12. Es inaplicable un tratado internacional que prevé la aplicación retroactiva de la ley penal —en el caso, las normas que declaran la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad—, en virtud del principio de legalidad que consagra el principio “nullum crimen nulla poena sine lege praeterita” —art. 18, Constitución Nacional—, el que debe ser respetado estrictamente, aun tratándose de crímenes de lesa humanidad juzgados en el país, criterio que se condice con la posición adoptada por la República Argentina al efectuar la reserva al art. 15, párr. 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Adla, XLVI-B, 1107) (del voto en disidencia del doctor Fayt).

13. No cabe aplicar la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (Adla, LXIII-E, 3843) en forma retroactiva —en el caso, a hechos de asociación ilícita con fines de persecución y exterminio de opositores políticos—, pues debe prevalecer el principio de legalidad contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional, ya que los arts. 27 y 75, inc. 22 prescriben que las disposiciones de los tratados internacionales con jerarquía constitucional no derogan artículo alguno de la Primera Parte de la Ley Fundamental (del voto en disidencia del doctor Vázquez).

CS, 2004/08/24. — Arancibia Clavel, Enrique L. (*).

Omissis...

Buenos Aires, 24 de agosto de 2004.

Considerando: 1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 condenó a Enrique Lautaro Arancibia Clavel a la pena de reclusión perpetua, como autor del delito previsto en el art. 210 bis, incs. a, b, d, f y h, del Código Penal (asociación ilícita agravada, versión ley 23.077) en concurso real con el de participación necesaria en el homicidio agravado por el uso de explosivos y con el concurso premeditado de dos o más personas de Carlos José Santiago Prats y Sofía Esther Cuthbert Chiarleoni (art. 80, incs. 2 y 4 del Código Penal, según ley 20.642).

2. Que a raíz del recurso interpuesto por la defensa la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal casó parcialmente el fallo mencionado, en cuanto había condenado por asociación ilícita agravada y declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito de asociación ilícita simple, sobreseyendo a Arancibia Clavel por este hecho.

Contra dicha decisión, la querella (en representación del gobierno de Chile) interpuso el recurso extraordinario, cuya denegación originó la presente queja.

3. Que en lo que aquí interesa la sentencia del tribunal oral tuvo por acreditado que

(*) Publicado en: LA LEY 10/11/2004, 8, María Angélica Gelli - LA LEY 09/09/2004, 7 - DJ 2004-3, 162, con nota de Augusto M. Morello - Sup. Const 2004 (octubre); 4, con nota de Marcela I. Basterra; Juan Cianciardo; Andrés Gil Domínguez; Horacio A. García Belsunce - RDM 2004-V, 119.

Enrique Lautaro Arancibia Clavel tomó parte a partir de marzo de 1974 y hasta el 24 de noviembre de 1978 de una asociación ilícita (la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA exterior), dependiente del gobierno de facto de Chile), que contaba con al menos 10 miembros, y cuya actividad consistía en la persecución de opositores políticos al régimen de Pinochet exiliados en Argentina. Esto incluía secuestros, sometimiento a interrogatorios bajo tormentos, sustracción de sus identificaciones para su reutilización previa falsificación, etc. Dentro de la organización, Arancibia Clavel, tenía por función formar en Buenos Aires una red paralela de informantes que aportaran datos sobre los perseguidos. Asimismo, estuvo presente durante el allanamiento y la aplicación de torturas a la ciudadana chilena Laura Elgueta, fueron encontrados en su poder documentos de identidad utilizados para dificultar la identificación de los asesinados, utilizaba identidades falsas y ocultaba sus actividades de inteligencia aparentando ser empleado del Banco de Estado de Chile.

4. Que al calificar la conducta de Arancibia Clavel de haber tomado parte en la asociación precedentemente descripta, el tribunal oral consideró, de conformidad con la posición postulada por el querellante, que resultaba aplicable al caso el tipo previsto en el art. 210 bis, Código Penal, en su redacción actual, que reprime más gravemente las asociaciones ilícitas que reúnan al menos dos características particulares (diez o más miembros, organización militar, disposición de armas de guerra o explosivos, uno o más miembros oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad, apoyo de funcionarios públicos), cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Como fundamento para aplicar el texto actual, tuvo en cuenta que en los delitos permanentes (como la asociación ilícita) la ley aplicable al momento de comisión es la de vigencia al momento del cese de la conducta delictiva; en el caso, el art. 210 bis vigente en 1978 preveía un tipo penal más gravoso (versión 21.338): “Se impondrá reclusión o prisión de cinco a doce años, si la asociación dispusiere de armas de fuego o utilizare uniformes o distintivos o tuviere una organización de tipo militar. La pena será de reclusión o prisión de cinco a quince años, si la asociación dispusiera de armas de guerra y tuviere una organización de tipo militar. Los cabecillas, jefes, organizadores o instructores serán reprimidos de ocho a veinticinco años de reclusión o prisión. La misma pena se im-

pondrá si la asociación estuviere organizada total o parcialmente con el sistema de células”, que, por aplicación de la ley más benigna (art. 2, Código Penal) quedaba desplazado por el actual art. 210 bis.

5. Que, en contra de ello, la Cámara de Casación afirmó que la conducta atribuida a Arancibia Clavel, por sus características, y con seguridad, al menos entre 1976 y 1978, “jamás pudo contribuir a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional”, en el sentido de poder contribuir efectivamente a afectar el sistema republicano y democrático, y concluyó que, por lo tanto, no resultaba aplicable el tipo penal del art. 210 bis, versión ley 23.077. Por su parte, el tipo penal en que sí podría haber resultado subsumible (art. 210 bis, versión ley 21.338) ya no se encontraba vigente, con lo cual sólo podía entrar en consideración el tipo básico del art. 210, por ser “la única disposición penal que define el comportamiento tanto al tiempo de iniciarse la ejecución del hecho como en el intermedio y en el del juzgamiento”. Respecto de dicho delito, sin embargo, resolvió que la acción penal se encontraba prescripta, por cuanto desde la fecha en que Arancibia dejó de cometer el delito (la de su detención, el 24 de noviembre de 1978) hasta la de su llamado a prestar declaración indagatoria (15 de mayo de 1989) transcurrieron más de diez años (arts. 59, inc. 3, 62, inc. 2, 63, 67 párr. 4 y 210 del Código Penal).

6. Que con relación a este último punto el a quo rechazó la posición de los querellantes con respecto a la imprescriptibilidad de los hechos imputados a Arancibia Clavel, por tratarse delitos de lesa humanidad, sobre la base de que en la sentencia no quedaban comprendidos los delitos que pudieran haber cometido los miembros de la banda, sino únicamente el haber integrado una asociación ilícita. Dicha conducta —afirmó— de ningún modo se ha demostrado que pueda encajar dentro de los “crímenes de lesa humanidad” que definió como “...los asesinatos, exterminación, sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, en ejecución o conexión con cualquier crimen de jurisdicción del Tribunal, sean o no una violación de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados...”. En su opinión, sólo se cuenta hasta el momento con definiciones inseguras, y “habrá de verse si acaso permitan superar la aludida inseguridad las

definiciones que acuña el estatuto de la Corte Penal Internacional...

7. Que la querrela fundó sus agravios ante esta Corte en el exceso de jurisdicción en que habría incurrido la cámara al resolver la inaplicabilidad del art. 210 bis a la conducta del imputado, cuando la cuestión no había sido expresamente planteada por la defensa, y cuestionó por arbitraria la interpretación que el a quo realizara de dicha norma y de la garantía de la ley penal más benigna.

8. Que tanto la cuestión relativa a la forma de introducción del planteo de la defensa, así como la atinente a la subsumción de la conducta imputada a Arancibia Clavel en el tipo penal previsto actualmente en el art. 210 bis del Código Penal de la Nación, remiten al examen de cuestiones de derecho procesal y común, ajenos a la vía del art. 14 de la ley 48. Por otra parte, y en cuanto al planteo de la arbitraria interpretación de la ley penal efectuada por el a quo, cabe destacar que tal arbitrariedad no se vislumbra en la sentencia impugnada, toda vez que la Cámara de Casación efectuó un análisis correcto de las exigencias del tipo penal aplicable, y por demás fundado, con lo que el agravio del recurrente, en este sentido, sólo se limita a fundar su discrepancia con el criterio adoptado.

9. Que si bien el agravio relativo a la imprescriptibilidad de las conductas imputadas a Arancibia Clavel, por su calidad de crímenes de lesa humanidad, fue introducido por la querrela ante la Cámara de Casación y no fue mantenido explícitamente en esta instancia, corresponde que sea tratado por la Corte toda vez que la prescripción de la acción penal constituye una cuestión de orden público y la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico interamericano. Asimismo, cabe señalar que como la sentencia impugnada ha tratado este tema que configura una cuestión federal, resulta inoficioso todo examen respecto de la forma y oportunidad de su introducción y mantenimiento en el proceso (Fallos: 306:1047).

10. Que la apreciación de la Cámara de Casación relativa a que la conducta de Arancibia Clavel de tomar parte en la asociación ilícita que integraba "de ningún modo se ha demostrado que pueda encajar dentro de los 'crímenes de lesa humanidad'" no puede compartirse. Se pretende dar sustento a tal afirmación en la circunstancia de que el objeto de la sentencia apelada no incluye los delitos que pudieran haber cometido los miembros de la banda (ni siquiera el homici-

dio de Prats y su esposa, objeto de otro recurso), sino tan solo la imputación por el art. 210, Código Penal, hecho que no estaría comprendido en ninguna de las definiciones de delitos de lesa humanidad que transcribe, y a las que califica, además, de "inseguras".

11. Que, estrictamente, y a partir de las propias definiciones utilizadas por el a quo correspondía calificar a la conducta de Arancibia Clavel como un delito de lesa humanidad, pues la agrupación de la que formaba parte estaba destinada a perseguir a los opositores políticos de Pinochet, por medio de homicidios, desaparición forzada de personas y tormentos (sobre cuyo carácter no caben dudas) con la aquiescencia de funcionarios estatales. En efecto, de acuerdo con el texto del Estatuto de Roma que en la resolución apelada cita sólo en su art. 7, queda alcanzada toda forma posible de intervención en esta clase de hechos. Así, no sólo quedan incluidas las formas "tradicionales" de participación (art. 25, inc. 3, aps. a, b y c), sino que expresamente menciona el contribuir "de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común" (art. 25, inc. 3, ap. d), cuando dicha contribución es efectuada "con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otra entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte" (ap. d, supuesto i).

12. Que, por otro lado, si lo que estaba en discusión era la imprescriptibilidad de una asociación ilícita cuyo objeto era la comisión de tales crímenes, el instrumento normativo que debía regir la interpretación era la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad" (conf. ley 24.584 y decreto 579/2003), que adquirió jerarquía constitucional por ley 25.778.

13. Que en este sentido no podría sostenerse que si los homicidios, la tortura y los tormentos, la desaparición forzada de personas, son delitos contra la humanidad, el formar parte de una asociación destinada a cometerlos no lo sea, pues constituiría un contrasentido tal afirmación, toda vez que este último sería un acto preparatorio punible de los otros.

Así, por ejemplo lo estatuyen los arts. 2, y 3 inc. b de la Convención para Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que incluye dentro de los actos castigados la "asociación para cometer genocidio".

De igual forma, se ha dicho que "la desaparición forzada de personas constituye una

violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los estados partes están obligados a respetar y garantizar", y ello sin perjuicio de la ley positiva del Estado que se trate, pues si bien no existía al tiempo de los hechos "ningún texto convencional en vigencia, aplicable a los Estados Partes en la Convención, que emplee esta calificación, la doctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la humanidad" (conf. Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988 Serie C Nº 4; luego reiterado en el caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C Nº 5; y recientemente en el caso Blake, sentencia del 24 de enero de 1998, Serie C Nº 36, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, conf. Preámbulo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas).

Desde esta perspectiva, podría afirmarse que la ratificación en años recientes de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por parte de nuestro país sólo ha significado, como ya se adelantara, la reafirmación por vía convencional del carácter de lesa humanidad postulado desde antes para esa práctica estatal, puesto que la evolución del derecho internacional a partir de la segunda guerra mundial permite afirmar que para la época de los hechos imputados el derecho internacional de los derechos humanos condenaba ya la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad. Esto obedece a "que la expresión desaparición forzada de personas no es más que un nomen iuris para la violación sistemática de una multiplicidad de derechos humanos, a cuya protección se había comprometido internacionalmente el Estado argentino desde el comienzo mismo del desarrollo de esos derechos en la comunidad internacional una vez finalizada la guerra (Carta de Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, la Carta de Organización de los Estados Americanos del 30 de abril de 1948, y la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 2 de mayo de 1948)" (dictamen del señor Procurador General en la causa M.960.XXXVII "Massera, Emilio Eduardo s/incidente de excarcelación", sentencia del 15 de abril de 2004).

Por otra parte el art. 7.1, inc. h, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, considera como crimen de lesa humanidad la

"Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte...".

Finalmente, luego de definir los crímenes imprescriptibles, el art. II de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, dispone "Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo I, las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participan como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que conspiran para cometerlos, cualquiera sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración".

14. Que del plexo normativo internacional transcrito se desprende que dentro de la clasificación de los crímenes contra la humanidad, también se incluye el formar parte de una organización destinada a cometerlos, con conocimiento de ello.

15. Que Arancibia Clavel fue condenado por el delito de asociación ilícita, toda vez que el tribunal de juicio dio por probado que el incuso formaba parte de un grupo destinado a perseguir reprimir y exterminar sistemáticamente a opositores políticos del régimen dictatorial instaurado en la República de Chile, a partir de septiembre de 1973 (DINA exterior), que operaba dentro del territorio nacional, y abarcó la comisión de homicidios, desapariciones forzadas, tormentos, falsificación de documentos, disposición de armas y explosivos, entre otros; asumiendo como función el encausado, al menos, el facilitar y apoyar los delitos del grupo por medio de la consolidación de una "red de informantes" y "contactos" con funcionarios policiales y militares destinados a obtener datos sobre posibles perseguidos y, en su caso, a garantizar la impunidad de los autores materiales de crímenes de lesa humanidad.

16. Que los delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos (entre los que debemos contar el formar parte de un grupo destinado a llevar

267

adelante esta persecución), pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, porque atentan contra el derecho de gentes tal como lo prescribe el art. 118 de la Constitución Nacional.

17. Que en consecuencia el formar parte de un grupo dedicado a perpetrar estos hechos, independientemente del rol funcional que se ocupe, también es un crimen contra la humanidad.

18. Que definida la asociación ilícita para perpetrar hechos considerados delitos de lesa humanidad, también pasa a ser un delito contra la humanidad, resta por verificar si la acción penal se encuentra prescripta o no.

19. Que el instituto de la prescripción de la acción penal, está estrechamente ligado al principio de legalidad, por lo tanto no sería susceptible de aplicación una ley ex post facto que alterase su operatividad, en perjuicio del imputado.

El rechazo de la retroactividad de disposiciones penales posteriores al hecho, las llamadas leyes ex post facto, que impliquen un empeoramiento de las condiciones de los encausados ha constituido doctrina invariable en la jurisprudencia tradicional de la Corte. En el caso "Mirás" (Fallos: 287:76, y sus numerosas citas sobre el punto) se señaló expresamente que tal principio alcanza también a la prescripción de la acción penal. Se dijo en esa ocasión: "el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de 'ley penal', desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva".

20. Que el fundamento común del instituto de la prescripción, independientemente del objeto al que aluda (de la acción o de la pena), es la inutilidad de la pena en el caso concreto, en los que el transcurso del tiempo entre el hecho y el juicio, o entre la condena y su ejecución, hace que la persona imputada no sea la misma, como así también que el hecho sometido a la jurisdicción pierda vigencia vivencial conflictiva, para pasar a ser un mero hecho histórico-aneecdótico. En definitiva escapa a la vivencia de sus protagonistas y afectados.

21. Que la excepción a esta regla, está configurada para aquellos actos que constituyen crímenes contra la humanidad, ya que se tratan de supuestos que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada la

magnitud y la significación que los atañe. Ello hace que no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad internacional misma.

En este sentido se ha dicho que "Tanto los 'crímenes contra la humanidad' como los tradicionalmente denominados 'crímenes de guerra' son delitos contra el 'derecho de gentes' que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar" (Fallos: 318:2148, voto de los jueces Nazareno y Moliné O'Connor).

22. Que en razón de que la aprobación de la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad" y su incorporación con jerarquía constitucional (ley 25.778) se produjo con posterioridad a la comisión de los hechos de la causa corresponde examinar la cuestión relativa a si la regla que establece la imprescriptibilidad de la imputación por el delito de asociación ilícita se aplicaría al sub lite retroactivamente o si ello lesiona el principio nulla poena sine lege.

23. Que el fundamento de la imprescriptibilidad de las acciones emerge ante todo de que los crímenes contra la humanidad son generalmente practicados por las mismas agencias de poder punitivo operando fuera del control del derecho penal, es decir, huyendo al control y a la contención jurídica. Las desapariciones forzadas de personas en nuestro país las cometieron fuerzas de seguridad o fuerzas armadas operando en función judicial; los peores crímenes nazis los cometió la Gestapo (Geheimnis Staatspolizei o policía secreta del Estado); la KGB estalinista era un cuerpo policial. No es muy razonable la pretensión de legitimar el poder genocida mediante un ejercicio limitado del mismo poder con supuesto efecto preventivo.

Por ello, no puede sostenerse razonablemente que sea menester garantizar la extinción de la acción penal por el paso del tiempo en crímenes de esta naturaleza.

24. Que el caso que nos ocupa no escapa a estas consideraciones ya que quedó demostrado que Arancibia Clavel formaba parte de una asociación denominada DINA exterior, que dependía directamente de la Dirección de Inteligencia Nacional del Estado chileno, y operaba en el territorio de la República Argentina. Es decir, que pertenecía a una agencia ejecutiva que operaba al margen del control jurisdiccional y del control del poder punitivo, no sólo dentro de las fronteras del Estado chileno, sino también fuera de él.

25. Que la doctrina de la Corte señalada en el precedente "Mirás" (Fallos: 287:76), se mantuvo inalterada a lo largo del tiempo y continúa vigente para la interpretación del instituto de la prescripción de la acción penal para el derecho interno, pero fue modificada con respecto a la normativa internacional en el precedente "Priebke" (Fallos: 318:2148), en el cual el gobierno italiano requirió la extradición de Erich Priebke para su juzgamiento por hechos calificables por tratados internacionales como "genocidio" y "crímenes de guerra", pero respecto de los cuales, desde la perspectiva del derecho interno, la acción penal se encontraba prescripta. A pesar de ello, esta Corte hizo lugar a la extradición, por entender que, conforme la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, no resultaban aplicables las reglas de la prescripción de la acción penal previstas en el Código Penal.

26. Que el Preámbulo de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad señala que una de las razones del establecimiento de la regla de la imprescriptibilidad fue la "grave preocupación en la opinión pública mundial" suscitada por la aplicación a los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios, "pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes". A ello se agrega el texto del art. IV, de conformidad con el cual los Estados Partes "se comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes mencionados en los arts. I y II de la presente Convención y, en caso de que exista, sea abolida". Tales formulaciones, si bien no resultan categóricas con respecto a la retroactividad de la convención, indican la necesidad de un examen de la cuestión de la prescripción diferenciada, según se trate o no de un delito de lesa humanidad.

27. Que la convención citada, constituye la culminación de un largo proceso que comenzó en los primeros años de la década de 1960 cuando la prescripción amenazaba con convertirse en fuente de impunidad de los crímenes practicados durante la segunda guerra mundial, puesto que se acercaban los veinte años de la comisión de esos crímenes.

28. Que esta convención sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función del derecho internacional público de origen consuetudinario. De esta manera, no se fuerza la prohibición de retroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos.

29. Que en rigor no se trata propiamente de la vigencia retroactiva de la norma internacional convencional, toda vez que su carácter de norma consuetudinaria de derecho internacional anterior a la ratificación de la convención de 1968 era ius cogens, cuya función primordial "es proteger a los Estados de acuerdos concluidos en contra de algunos valores e intereses generales de la comunidad internacional de Estados en su conjunto, para asegurar el respeto de aquellas reglas generales de derecho cuya inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema legal" (Fallos: 318:2148, voto de los jueces Nazareno y Moliné O'Connor).

Desde esta perspectiva, así como es posible afirmar que la costumbre internacional ya consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad a la convención, también esta costumbre era materia común del derecho internacional con anterioridad a la incorporación de la convención al derecho interno.

30. Que las cláusulas de los tratados modernos gozan de la presunción de su operatividad, "por ser, en su mayoría, claras y completas para su directa aplicación por los Estados partes e individuos sin necesidad de una implementación directa"; y además, "la modalidad de aceptación expresa mediante adhesión o ratificación convencional no es exclusiva a los efectos de determinar la existencia del ius cogens. En la mayoría de los casos, se configura a partir de la aceptación en forma tácita de una práctica determinada" (Fallos: 318:2148, voto del juez Bossert).

31. Que al momento de los hechos, el Estado argentino ya había contribuido a la formación de la costumbre internacional a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad (conf. Fallos: 318:2148, voto del juez Bossert, considerando 88 y siguientes).

32. Que de acuerdo con lo expuesto y en el marco de esta evolución del derecho internacional de los derechos humanos, puede decirse que la Convención de Imprescriptibili-